

사용자의 의미와 교섭창구단일화에 대한 검토

— 개정 노조법의 쟁점을 중심으로 —

박 귀 천* · 박 은 정**

목 차

- I. 서론
- II. 사용자 개념에 관한 검토
- III. 교섭창구단일화제도에 대한 검토
- IV. 결론

I. 서론

현행(2026년 3월 10일 이전) 「노동조합 및 노동관계조정법」(이하 “노조법”)은 “사용자라 함은 사업주, 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 말한다.”라고 규정하고 있다. 이는 사용자 개념의 실질적 내용 자체를 정의하기보다는 사용자를 세 개의 유형으로 분류하여 제시한 규정으로 이해할 수 있다. 따라서 “사업주”, “사업의 경영담당자”, “근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자” 각각의 의미와 범위에 대해서는 오래전부터 판례와 학설을 통해 구체적 해석이 축적되어 왔다.

학설의 경우 근로계약 체결 당사자인 사업주가 아니더라도 근로조건에 실질적 영향력을 행사하는 외부 기업을 단체교섭상의 사용자 또는

투고일 2025. 11. 20., 심사일 2025. 12. 4., 게재확정일 2025. 12. 13.

* 제1저자: 이화여자대학교 법학전문대학원 교수

** 교신저자: 한국방송통신대학교 법학과 교수

부당노동행위 주체로 인정해야 하는 경우가 존재한다고 보아 왔다. 이는 노동관계의 실질적 구조에 대응하여 사용자 개념을 확대하려는 시도였다. 특히 단체교섭의 맥락에서, 교섭을 신청한 노동조합 조합원의 근로계약상 사용자, 즉 고용주가 아니라 하더라도 고용주와 근접·유사한 지위에서 근로조건에 실질적으로 영향을 주는 자는 일정 범위 내에서 단체교섭 당사자로 보아야 한다는 견해가 지배적이었다. 이러한 입장은 2000년대 초반 주요 노동법 교과서들에서 공통적으로 확인된다.¹⁾

사용자 개념 확대에 관한 판례의 사실상 리딩케이스는 원청의 하청노동자에 대한 부당노동행위 책임이 문제된 대법원 2010. 3. 25. 선고 2007두8881 판결(현대중공업 사건)이다. 그러나 교섭창구단일화 제도 시행 이전에도 단체교섭상 사용자 개념을 확장한 하급심 판결과 가처분 결정이 존재하였다(대구고등법원 2007. 4. 5. 선고 2006노595 판결; 서울남부지방법원 2007. 12. 10.자 2007카합2731 결정; 대전지방법원 2011. 10. 6.자 2011카합782 결정 참조). 또한 교섭창구단일화 제도 시행 이후에도 원청의 교섭의무를 인정한 중앙노동위원회 판정과 이를 적법하다고 본 고등법원 및 행정법원 판결들이 누적되어 왔다(중앙노동위원회 2021부노14(씨제이대한통운 사건), 2021부노268(현대제철 사건), 2022.12.20. 판정(한화오션 사건); 서울고등법원 2024. 1. 24. 선고 2023누34646 판결; 서울행정법원 2025. 7. 25. 선고 2022구합69230 판결; 서울행정법원 2025. 7. 25. 선고 2023구합55658·56231 판결 참조). 아울러 기획폐업 등 원청의 부당노동행위가 문제된 사안에서 원청이 부당노동행위 주체로서 사용자로 인정된 판결이 대법원에서 확정된 사례도 존재한다(서울고등법원 2020. 8. 10. 선고 2020노115 판결; 대법원 2021. 2. 4. 선고 2020도11559 판결 참조).

주지하듯, 2026. 3. 10. 시행되는 개정 노조법 제2조 제2호 후단은 “근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 그 범위에서 사

1) 임종률, 『노동법』, 박영사, 2004, 110쪽; 김형배, 『노동법』, 박영사, 2003, 758쪽 이하; 이병태, 『노동법』, 중앙경제, 2001, 225쪽 이하; 김유성, 『노동법Ⅱ』, 법문사, 2000, 316쪽 이하.

용자로 본다.”라고 규정함으로써, 형식적 근로계약 당사자가 아닌 자에게도 일정한 경우 사용자성을 인정하는 내용을 명문으로 도입하였다. 이 규정의 신설은 노조법 전반에 걸쳐 해석론적·정책적 변화를 요구하며, 각 조항별 적용 방식 및 집단적 노사관계 제도 설계에도 영향을 미칠 것으로 예상된다.

이에 본 글은 사용자 개념 확장의 법적 의미를 검토하고, 특히 사용자성 확대와 교섭방식의 관계를 중심으로 분석한다. 즉, 개정법 제2조 제2호 후단에 규정된 사용자 개념의 판단 기준을 기존 판례와 중앙노동위원회 판정에 비추어 검토하고, 원청이 사용자로 인정되는 경우 교섭창구단일화 제도와와의 관계, 나아가 법령 및 제도 개선의 필요성을 논한다.

II. 사용자 개념에 관한 검토

여기에서는 먼저 사용자 개념과 관련된 주요 판례를 대법원, 고등법원, 지방법원 순으로 체계적으로 검토하고, 이러한 판례들이 제시하는 판단 기준과 해석 경향을 분석한다. 나아가 이 판례 분석을 토대로 개정 노조법 제2조 제2호 후단이 도입한 사용자 개념의 해석론과 그 적용 방향에 대하여 논하고자 한다. 다만, 이하에서 검토하는 판례들 대부분은 이미 다른 선행연구에서 상세하게 다루어진 경우가 많기 때문에 이 글에서는 각 판례에서 문제되는 모든 쟁점들을 분석하는 것이 아니라 사용자성 판단 기준과 관련하여 고려할만한 점들에 한하여 살펴본다.

1. 관련 판례 검토

1) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2007두8881 판결

(1) 판결 내용

2007두8881 판결은 “지배·개입 주체로서의 사용자인지 여부도 당해 구제신청의 내용, 그 사용자가 근로관계에 관여하고 있는 구체적 형태,

근로관계에 미치는 실질적인 영향력 내지 지배력의 유무 및 행사의 정도 등을 종합하여 결정하여야 할 것이다. 따라서 근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 그 근로자를 고용한 사업주로서의 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도로 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자가, 노동조합을 조직 또는 운영하는 것을 지배하거나 이에 개입하는 등으로 법 제81조 제4호 소정의 행위를 하였다면, 그 시정을 명하는 구체명령을 이행하여야 할 사용자에게 해당한다.”라고 판시했다. 다만, 구체적 판단과 관련하여서는 세부적인 판단 기준 내지 판단요소는 제시하지 않고, 아래와 같이 인정된 사실관계들을 종합하여 원청을 사용자로 판단했다.

- ① 원고 회사가 공정의 원활한 수행 및 품질관리 등을 위해서 사내 하청업체 소속 근로자들이 해야 할 작업 내용 전반에 관하여 직접 관리하고 있었고, 또 개별도급계약을 통하여 작업 일시, 작업 시간, 작업 장소, 작업 내용 등에 관하여 실질적·구체적으로 결정하는 등 원고 회사가 작업시간과 작업 일정을 관리·통제하고 있기 때문에 근로자들이 노동조합의 총회나 대의원대회 등 회의를 개최하기 위하여 필요한 노조활동 시간 보장, 노조간부의 유급 노조활동시간 보장 등에 대하여 실질적인 결정권을 행사하게 되는 지위에 있는 점,
- ② 사내 하청업체는 위와 같은 작업 일시, 장소, 내용 등이 개별도급계약에 의해 확정되기 때문에 사실상 이미 확정되어 있는 업무에 어느 근로자를 종사시킬지 여부에 관해서만 결정하고 있던 것에 지나지 않았던 점,
- ③ 사내 하청업체 소속 근로자는 원고 회사가 제공한 도구 및 자재를 사용하여 원고 회사의 사업장 내에서 작업함으로써 원고 회사가 계획한 작업 질서에 편입되고 원고 회사 직영근로자와 함께 선박 건조업무에 종사하고 있었던 점,
- ④ 작업의 진행방법, 작업시간 및 연장, 휴식, 야간근로 등에 관하여서도 위 근로자들이 실질적으로 원고 회사 공정관리자(직영반장이나 팀장)의 지휘·감독하에 놓여 있었던 점.

(2) 특징 및 시사점

이 판결에서는 작업 내용, 작업 시간, 작업 장소 등에 관하여 원청이 관리·통제, 하청업체의 결정 권한 정도, 원청이 계획한 작업 질서예의 편입, 원청근로자와 하청근로자가 함께 업무에 종사, 작업 진행방법 및 근로시간에 관한 원청의 지휘·감독 등의 사실인정을 통해 원청의 사용자성이 인정되었다.

그런데 법원이 구체적인 판단 요소들을 제시하지 않으면서 인정된 사실관계들을 종합하여 원청의 사용자성을 판단했다는 점은 다른 사건에서도 반드시 이 판결에서 문제된 사실관계와 같은 정도의 사정들이 모두 인정되어야만 사용자라고 보는 것은 아니라고 해야 할 것이라는 점을 유의해야 한다. 물론 다른 사건에서 이 판결에서 인정된 사실관계와 같은 상황이 모두 충족된다면 원청의 사용자성이 인정될 가능성은 매우 높을 것이다.

2) 대구고등법원 2007. 4. 5. 선고 2006노595 판결

(1) 판결 내용

대구고등법원은 2006노595 판결에서 건설일용노동자들의 노동조합에 대해 원청업체가 단체교섭의무를 부담하는 사용자로 인정했다. “단체교섭의 당사자로서의 사용자라 함은 근로계약관계의 당사자로서의 사용자에게 한정되지 않고 비록 근로계약관계의 당사자가 아니더라도 단체교섭의 대상이 되는 근로조건에 관한 사항의 전부 또는 일부에 대하여 구체적·실질적 영향력 내지 지배력을 미치는 자도 단체교섭의 의무를 부담하는 사용자에게 해당한다고 할 것”이라고 판시하면서 다음과 같은 점들을 판단의 근거로 제시했다.

- ① 현장을 중심으로 이루어지는 건설근로의 경우 그 특성상 원청업체와 건설일용노동자들과의 사이에 직접적인 근로계약관계를 맺고 있지는 않지만 통상 원청업체는 이러한 노동자들의 노무 제공의 모습, 작업 환경, 근무시간의 배정 등을 실질적으로 결정하는 등으로 노동자들의 기본적인 근로조건 등에 관하여 고용주인 하도급업

자, 재하도급업자 등과 동일시할 수 있을 정도로 현실적이고 구체적인 지배를 하는 지위에 있다고 볼 수 있는 점,

- ② 특히 법률상 원청업체의 책임이 인정되는 임금지급에 대한 연대책임, 산업안전·보건관리에 관한 조치의무와 산재보험의 적용, 퇴직공제가입 등에 대한 부분과 원청업체가 실질적인 권한을 행사하는 부분에 있어서는 최소한 원청업체에 단체교섭 당사자로서의 지위를 인정할 수 있다는 점.

(2) 특징 및 시사점

이 판결에서는 원청이 노무 제공의 모습, 작업 환경, 근무시간의 배정 등을 실질적으로 결정한다는 점이 근거로 제시되었다. 임금 지급에 대한 연대책임, 산업안전·보건관리에 관한 조치의무 등 법률상 원청의 책임이 인정되는 하청 근로자들의 근로조건에 대한 부분에 관해서는 원청의 단체교섭 당사자로서의 지위를 인정할 수 있다고 보았다는 점에서 법률에서 원청의 의무와 책임으로 규정하고 있는 사항이 교섭의제가 되는 경우 법률에 규정이 있다는 점은 원청의 하청 노조에 대한 실질적·구체적 지배·결정을 인정하는 중요한 근거가 될 수 있음을 보여주고 있다.

3) 서울고등법원 2020. 8. 10. 선고 2020노115 판결(대법원 2021. 2. 4. 선고 2020도11559 판결)

(1) 판결 내용

서울고등법원은 2020노115 판결에서 “노동조합법상 부당노동행위 관련 규정 내용과 취지 등에 비추어 보면, 노동조합법 제81조의 ‘사용자’에는 근로자와 직접 근로계약을 맺은 당사자뿐만 아니라, 근로자와 직접 근로계약을 맺지는 않았지만 근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 그 근로자를 고용한 사업주로서의 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도로 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자라면 노동조합법상 부당노동행위의 주체로서 처벌의 대상이 되는 사용자에게 해당한다고 할 수 있다.”라고 판시했다.

이 사건에서는 하청근로자들이 원청에 대해 불법과건과 부당노동행위를 주장하였는데 불법과건은 부정된 반면 원청의 노조법 위반은 인정되었다.

(2) 특징 및 시사점

이 판결에서는 원청의 불법과건 해당 여부와 노조법상 사용자성 해당 여부를 구분하여 양자는 별개의 판단을 요하는 문제임을 확인했다는 특징이 있다. 불법과건 해당 여부를 판단함에 있어서는 불법과건 판단기준에 대한 기존 판례와 마찬가지로 원청이 하청근로자들에 대해 직·간접적으로 그 업무수행 자체에 관한 구속력 있는 지시를 하는 등 상당한 지휘·명령을 하였는지 여부에 관하여 판단한 반면, 하청근로자에 대한 원청의 부당노동행위 주체로서의 사용자성, 즉, 노조법상 사용자성을 판단함에 있어서는 지휘·명령 여부에 대해 판단하지 아니한 것이다.²⁾

‘임금’에 관한 판단에서는 불법과건 여부를 판단할 때에는 하청이 독자적인 임금체계를 갖추고 그에 따라 산정한 임금을 수리기사들에게 지급한 사정을 중시하였으나, 노조법상 사용자성 여부를 판단할 때에는 “협력업체는 피고인으로부터 받은 위탁비의 범위 내에서 수리 실적에 따라 소속 수리기사들에게 임금을 지급한다. 따라서 피고인이 정한 위탁비 기준 및 단가는 협력업체 소속 수리기사들의 임금에도 간접적으로 영향을 미칠 수밖에 없었다.”라고 판시하여 원청이 정한 위탁비 기준 및 단가가 협력업체 소속 수리기사들의 임금에 ‘간접적으로 영향’을 미칠 수밖에 없다는 사정을 실질적 지배·결정의 징표로 인정했다.³⁾

한편, 하청업체가 자기 자본으로 설립 자본금을 마련하고, 그 소유의 자산 보유, 업무 수행에 필요한 일부 재료를 자체적으로 구입하여 사용하는 등 독자적인 실체를 가지고 있는 사정들이 인정되더라도 하청업체의 업무 및 사업 존속이 전적으로 원청과의 위탁업무계약에 의존하고 있다면, 원청의 하청근로자에 대한 실질적 지배력 내지 영향력이 미칠

2) 김민기, “사내하청에 대한 노동법적 규율”, 서울대학교 박사학위논문, 2023, 269쪽.

3) 김민기, 앞의 논문, 269쪽.

수 있다고 판단했다. 즉, 하청의 기업으로서의 독립성은 원청의 노조법상 사용자성 판단에서 고려요소가 되지 않았다.⁴⁾

4) 서울고등법원 2024. 1. 24. 선고 2023누34646 판결

(1) 판결 내용

서울고등법원은 2023누34646 판결에서 원청의 사용자성을 인정한 중앙노동위원회 재심 판정 및 1심 행정법원 판결의 입장을 유지하면서 “부당노동행위는 근로계약상의 위법행위가 아니라 집단적 노사관계법에 특유한 위법행위인바, 현실적인 근로계약의 당사자인가 여부로서 사용자 개념의 기준을 도출하여야 한다고 볼 수 없다. 노동조합법상 단체교섭의무를 부담하는 사용자에 해당하는지 여부는 기본적으로 헌법상 기본권인 단체교섭권을 구체적으로 실현하는 관점에서 파악하여야 할 것인데, 단체교섭의 대상인 근로조건 등을 지배·결정하는 자와 단체교섭이 이루어지지 않는다면 사용자와 대등한 지위에서 집단적 교섭을 통해 근로조건 등을 결정·개선할 수 있도록 하는 단체교섭권이 실질적으로 기능하지 못하게 된다.”라고 하면서 “근로자에 대한 해석은 필연적으로 사용자에 대한 해석과 연결된다 할 것인데, 노무제공관계의 실질에 비추어 노동3권을 보장할 필요성이 있는지를 주요 판단요소로 고려하는 노동조합법상 근로자 개념의 해석에 조응하여(대법원 2018. 6. 15. 선고 2014두12598, 12604 판결 등 참조) 노동조합법상 사용자 여부 또한 노무제공관계의 실질에 비추어 노동3권을 침해할 수 있는 권한·지위에 있는지의 관점에서 파악하여야 한다고 봄이 자연스럽다.”라고 판시했다.

한편, 이 판결의 1심 판결인 서울행정법원 2023. 1. 12. 선고 2021구합71748 판결에서는 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에 해당하는지에 대해 사업주가 근로조건인 교섭요구사항에 대하여 실질적으로 결정하거나, 근로자가 해당 근로조건을 사업주의 의사대로 또는 정해진 대로 복종하여 따를 수밖에 없어 사업주가 해당 근로조건을 지배하고 있는지를 기준으로 판단해야 하고, 그러한 판단을 함에 있어서는 원고와 집배점의

4) 김민기, 앞의 논문, 270쪽.

관계, 집배점 택배기사의 업무가 상시적·필수적인 업무인지, 원고의 사업체계의 일부로 편입됨으로써 근로조건을 지배하거나 결정하는 원고의 지위가 지속적인지 등을 종합적으로 고려하여야 한다고 실시했다.⁵⁾

(2) 특징 및 시사점

이 사건에서는 ① 원청과 하청의 관계, ② 하청근로자 업무가 상시적·필수적 업무인지, ③ 원청의 사업체계의 일부로 편입 및 그로 인해 원청이 하청 근로자의 근로조건을 지속적으로 지배하거나 결정하는지가 판단 요소로 제시되었으며, 각 교섭의제별로 사용자성 판단한다는 점을 확인할 수 있다. 이 사건에서 중앙노동위원회, 서울행정법원, 서울고등법원은 모두 각 교섭의제별로 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는지 여부를 판단한다는 입장을 취했다.⁶⁾

5) 서울행정법원 2025. 7. 25. 선고 2022구합69230 판결 및 서울행정법원 2025. 7. 25. 선고 2023구합55658·2023구합56231 판결

(1) 판결 내용

2025년 7월 25일에 내려진 두 개의 행정법원 판결⁷⁾은 노조법 제81조 제3호 및 제4호의 사용자라 함은 “근로자를 고용한 사업주로서의 권한 및 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도로 근로조건 등을 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자”라고 실시했고,

5) 이 사건의 중앙노동위원회 재심 판정에서는 “이 사건 대리점 택배기사의 노무가 이 사건 사용자의 사업 수행에 필수적이고 그 사업체계에 편입되어 있는지 여부, 이 사건 대리점 택배기사의 노동조건 등을 단체교섭에 의해 집단적으로 결정하여야 할 필요성과 타당성 등을 종합적으로 고려하여야 할 것”이라고 밝혔다(중앙노동위원회 2021. 6. 2. 판정 2021부노14).

6) 교섭의제: ① 서브터미널에서 배송상품 인수시간 단축, ② 서브터미널에서 집화상품 인도시간 단축, ③ 서브터미널 작업환경 개선(택배기사 1인당 1주차장 보장, 우천시 상품 보호 시설 설치), ④ 주5일제 실시, ⑤ 급지수수료 인상·개선, ⑥ 사고부책 개선.

7) 서울행정법원 2025. 7. 25. 선고 2022구합69230 판결 및 서울행정법원 2025. 7. 25. 선고 2023구합55658·2023구합56231 판결.

그 주요 논거는 다음과 같다.

- ① 다면적 노무제공관계의 확산, 특히 대규모의 자본과 노동력의 투입이 요구되고 공정이 세분화 되어 있는 제조업, 건설업 분야에서 다면적 노무제공관계가 문제된다는 점(원청이 생산공정의 효율성, 인건비 절감, 고용 유연화 등의 이유로 사내하청을 활용하는 경우가 많고, 그에 따라 하청업체와 근로계약을 체결한 근로자에 대해서도 실질적인 작업지시나 감독은 원청의 관리자에 의해 이루어지며, 하청 소속 근로자들이 원청의 사업을 위한 제작 공정에서 필수적인 역할을 수행),
- ② 노동3권은 법률이 없더라도 헌법의 규정만으로 직접 법규범으로서 효력을 발휘할 수 있는 구체적 권리인바, 어떠한 사용자가 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자인지 여부는 기본적으로 단체교섭을 요구하는 근로자가 근로조건의 향상을 위하여 누구와 단체교섭을 할 수 있어야 하는지를 중심에 두고 판단하는 것이 합헌적 법률해석의 원칙에 부합된다는 점,
- ③ ILO는 하청 근로자가 자신의 근로조건을 결정할 수 있는 원청에 대하여 단체교섭권을 가진다고 인정하고 있으며, 단체교섭의 상대방인 사용자에게 해당하는지 여부에 있어 형식적 근로계약관계의 유무에 국한되지 않고 기능적·실질적인 해석을 하고 있다는 점,
- ④ 지배·개입의 부당노동행위와 단체교섭 거부 of 부당노동행위에 있어 사용자 개념을 동일하게 파악하는 것이 노동조합법 조문과 체계의 정합성에 부합된다는 점.

원청이 사내하청업체 근로자에 대하여 노동조합법상단체교섭 의무를 부담하는 사용자에게 해당하는지 여부는, 교섭 요구 의제에 대하여 원청이 실질적이고 구체적으로 지배·결정하는 지위에 있는지, 사내하청업체 근로자들의 노무가 원청의 사업 수행에 필수적이고 사업체계에 편입되어 있는지, 사내하청업체 근로자들의 노동조건 등을 원청과의 단체교섭에 의해 집단적으로 결정할 필요성과 타당성이 있는지 여부 등을 기준으로

판단하여야 하고, 위와 같은 판단을 함에 있어 사내하청업체 근로자들의 업무가 이 사건 사업장에서 행해지는 원청의 사업에서 차지하는 비중, 사내하청업체 근로자의 근무방식과 이에 대한 원청의 직·간접적 관여 정도, 원청과 사내하청업체의 관계 등을 종합적으로 고려하여야 한다고 판시했다. 다만, 2022구합69230 판결과는 달리 2023구합55658·2023구합56231 판결에서는 이러한 판단 요소에 더하여 사내하청업체의 경제적 독립성도 판단 요소로 제시하였다는 점에서 차이가 있다.

또한 하청 근로자에 대한 원청의 사용자성을 인정한 중노위 판정, 행정법원, 서울고등법원 마찬가지로 각 교섭의제별로 사용자성 판단하는 입장을 보였다. 2022구합69230 판결에서 원청의 사용자성 인정의 근거로 제시된 인정 사실을 좀더 구체적으로 살펴보면 아래와 같다.⁸⁾

- ① 원청의 사내하청업체 근로자의 업무를 수행방식에 따르면 사내하청업체 근로자에게 내려지는 업무지시는 원청으로부터 직접 이루어지고, 사내하청업체는 업무의 내용이나 방식에 대하여 실질적인 결정 권한을 보유하고 있지 않은 것으로 보임.
- 사내하청업체가 원청으로부터 수령하는 작업의뢰서에는 작업 상세 내역, 작업 대상과 유형, 수행 위치, 예정일 등이 기재되어 있고, 사내하청업체 근로자는 이를 바탕으로 정비 작업을 수행
- 사내하청업체 근로자가 구체적으로 해야 하는 작업의 내용은 사내하청업체와 원청 사이에 체결된 도급계약에 의해 구체적으로 특정된 것이 아니라 MES(Manufacturing Execution System), 무

8) 이 사건에서 하청노조는 원청에 대해 ① 산업안전보건, ② 차별시정, ③ 직접고용 원칙 및 불법파견 정규직 전환, ④ 자회사 채용 중단의 4가지 교섭의제에 대한 단체교섭을 요구하였는데 서울행정법원은 (원청)만이 이 사건 재심판정의 위법 여부를 다투며 그 취소를 구하고 있는 이 사건에 있어 산업안전보건 의제를 제외한 나머지 의제에 대한 중앙노동위원회 판단의 당부는 이 사건의 결론에는 영향을 주지 아니하는 점, 산업안전보건 의제를 제외한 나머지 의제에 대하여 원고 회사가 실질적 지배력을 행사하고 있는지 여부는 이 사건에서 주된 쟁점이 되지도 않은 점 등을 고려하여 산업안전보건 의제를 제외한 나머지 의제에 관하여는 별도로 판단하지 않았다.

- 전기, 유선전화, 카카오톡 등 메신저, 작업지시서 등을 통한 원고 회사 소속 근로자들의 지시에 의하여 구체적으로 특정되었고, 사내하청업체 소속 근로자들은 위 지시에 따라 해당 업무를 수행
- ② 원청은 사내하청업체의 인력 운용 효율성 제고를 위한 방안을 지속적으로 검토하였고, 사내하청업체 근로자의 구체적인 투입과 배치에 관한 사항을 결정하기도 하였음.
 - ③ 원청은 이 사건 사업장에서 사용되는 생산수단 일체를 소유하고 있음. 생산에 필수적인 대형 설비에 대한 관리처분 권한이 전혀 없는 사내하청업체가 이 사건 사업장에서 발생하는 노동안전 문제에 관하여 제시할 수 있는 해결책은 한정적임.
 - ④ 원청은 안전 기준에 관한 각종 지침 등을 제정하고 주기적인 안전 평가를 실시하고 있는데, 원청이 제정한 안전 관련 지침은 사내하청업체 근로자에게도 동일하게 적용되고, 위반에 대한 제재 조치와 안전평가 등이 원청 소속 근로자와 사내하청업체 소속 근로자에 대하여 동일하게 이루어졌음.
 - ⑤ 원청이 이 사건 사업장의 설비, 작업내용, 작업방식, 작업일정 등이 사건 사업장 내에서 근무하는 모든 근로자들의 안전과 관련한 요소를 지배·통제하고 있는 이상, 원청이 사내하청업체에 대한 안전 관련 지침을 마련하거나 그 이행을 감독하는 것이 관련 법령에 따른 도급인의 의무 이행이라는 측면을 가지고 있다고 하더라도 그러한 사정만으로 원고 회사의 실질적인 지배력이 부인될 수 없음.

한편, 2023구합55658·2023구합56231 판결에서 서울행정법원은 이 사건에서 전체가 하나의 생산라인인 것처럼 유기적으로 작동하고 있는데, 생산 공정에 있어 사내하청업체에 대한 높은 의존도에 비추어 사내하청업체들이 담당하는 각 수급업무 역시 원고 회사의 전체적인 제조 공정 내에서 유기적으로 조직되고 통합된 일부로서 기능하고 있다고 보인다는 점, 사내하청업체 근로자들은 외형상 독립된 하청업체 소속 근로자임에도 불구하고, 수행 업무의 실질적 내용과 조직 내 배치에 따라 원고 회사의 사업 내 조직의 일원처럼 인식되고 있는 것으로 보인다는 점, 사

내하청업체 근로자에 대하여 메신저, 이메일 등을 통한 업무 지시를 하기도 하였다는 점 등을 원청의 사용자성 인정의 근거로 제시했다. 이 사건에서 하청노조는 원청에 대해 ① 성과급 지급, ② 학자금 지급, ③ 노동조합 활동 보장, ④ 노동안전, ⑤ 취업방해 금지'의 5가지 의제에 대한 단체교섭을 요구했는데, 서울행정법원은 근로조건과 관련된 ①, ②, ④ 의제에 대해서는 원청이 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있으나, ③, ⑤ 의제에 대해서는 그러한 지위에 있다고 볼 수 없다고 판단했다. 원청의 사용자성 인정의 근거로 제시된 인정 사실은 아래와 같다.

- 제1, 2 의제(성과급 및 학자금 지급): 사용자성 인정
 - 원청의 사내하청업체들은 원청이 정한 성과급 총액의 범위 내에서 각 업체별로 배정된 금액을 교부받고, 교부받은 금액을 소속 근로자들에게 성과급 명목으로 지급.
 - 원청과 참가인 노동조합 원청 지회 사이의 종전 노사 합의 내용을 살펴보면, 사내하청 근로자들에 대한 성과급 등 처우에 관한 사항이 장기간에 걸쳐 노사 간 교섭 및 합의의 대상이 되어 왔음.
 - 사내하청업체들은 원청으로부터 학자금 총액을 교부받은 후 이를 다시 소속 근로자들에게 근속 연수를 기준으로 학자금 명목으로 지급함.
 - 원청은 사내하청업체들의 인력 현황, 작업 능률 등을 검토하고, 이에 기초하여 사내하청업체들에 대한 실질적인 관리를 해 온 것으로 보임.
 - 학자금 지급이 장기간에 걸쳐 반복적으로 지속되어 사내하청업체 근로자의 급여 중 상당한 부분을 차지하게 되었음.
- 제3 의제(노동조합 활동 보장): 사용자성 부정
 - 하청업체들은 원청과 체결한 개별 임대차계약에 따라 사업장 내부에 일정한 사무공간을 확보하고 있으므로, 필요할 경우 해당 공간의 일부를 노동조합에 제공하거나, 임대차계약의 변경 또는 추가

계약을 통하여 추가적인 공간을 확보할 수도 있을 것으로 보임. 사업장 부지 전체를 관리·통제하는 원청의 승낙 여부가 문제된다고 하더라도, 이는 원청과 하청의 개별적인 합의나 별개의 임대차 계약을 통하여 해결할 문제임.

- 원청이 행사하는 ‘실질적 지배력’은 특정 사안에 대하여 개입하거나 특정 근로조건을 결정하는 것이지, 원청이 특정 영역에 있어 실질적 지배력을 행사하고 있다고 하여 곧바로 하청노동조합의 조직 운영 전반에 대하여 사용자의 지위에서 포괄적으로 지배력을 행사하고 있다고 볼 수는 없음. 특히 노동조합 사무실의 설치나 사업장 내 출입은 노동조합의 조직적 독립성과 운영 자율성을 전제로 하여 기본적으로 하청업체와의 교섭 및 협의를 통해 해결되어야 할 사항임.

- 제4 의제(노동안전): 사용자성 인정

- 사내하청업체 소속 근로자들은 이 사건 사업장 내에서 작업을 수행함에 있어 원청이 정한 안전관리 절차 및 기준을 준수해야 함.
- 원청은 이 사건 사업장에 근무하는 인원 전체에 대하여 적용되는 안전 관련 규정 외에도, ‘협력회사 안전보건 관리 규칙’, ‘협력회사 정기안전보건협의회 운영규칙’ 등 사내하청업체 및 그 소속 근로자의 안전과 보건에 관한 사항을 독립적으로 규율하는 별도의 내부 규정을 직접 제정하여 적용함.
- 이 사건 사업장 내에서 안전사고가 발생하면 해당 사고는 원청의 안전담당팀과 참가인 조합 원청 지회 소속 노동안전팀에 동시에 공유되며, 이후 양측은 사고 현장에 직접 출동하여 사고 발생 경위 등을 조사하고, 사고 원인 분석(RCA, Root Cause Analysis) 및 재발방지 대책 수립 과정을 공동으로 수행함.

- 제5 의제(‘취업 방해 행위 금지’, ‘블랙리스트 작성 금지’): 사용자성 부정

- 취업 방해 행위, 블랙리스트 작성은 “누구든지 근로자의 취업을 방

해할 목적으로 비밀 기호 또는 명부를 작성·사용하거나 통신을 하여서는 아니 된다.”라고 규정하고 있는 근로기준법 제40조에 의하여 명시적으로 금지되는 행위에 해당함. 위 근로기준법 규정은 수범자의 범위를 한정하지 않고 모든 사람에 대하여 적용되므로, 그 준수 의무는 근로조건에 대한 실질적 지배력 여부, 단체협약체결 여부와는 무관하게 부과됨.

(2) 특징 및 시사점

기존에 하청 근로자에 대한 원청의 단체교섭 의무를 인정했던 판결 및 판결들에서 제시되었던 판단 요소들에 더하여 하청근로자들의 업무가 원청 사업에서 차지하는 비중, 하청 근로자의 근무 방식과 이에 대한 원청의 직·간접적 관여 정도, 하청의 경제적 독립성이 판단 요소로 제시되었다.

특히 같은 날 내려진 두 개의 판결 중 2023구합55658·2023구합56231 판결에서만 “하청의 경제적 독립성”을 언급하였다는 점이 특이하다. 이 판결에 따르면 문제된 사내하청업체는 “중앙노동위원회의 현장조사에서 사내하청 협력사는 ① 수급업무 수행의 핵심적인 장비들을 원청으로부터 사용대차 형식으로 제공받고, 원청이 당해 장비들에 대한 유지·보수·교체 등을 담당하며, ② 통상 소액의 임료를 지급하고 원청으로부터 임차한 사무실에 5명 내외의 사무직 근로자들이 근무하고 있고, ③ 거의 모든 사내하청 협력사들은 다른 도급인과 별건의 도급계약을 체결하지 않고 원청의 선박 건조에 관한 수급 업무만을 수행하는 것으로 나타났는바, 원고 회사와 도급계약을 체결한 사내하청업체들(특히 참가인 조합에 소속된 직접 생산 공정에 관여하는 사내하청업체)은 대부분 규모의 영세성, 조선업종의 특수성 등으로 인하여 원고 회사와 전속적인 거래관계에 있었고, 경제적으로도 사실상 종속되어 있었던 것으로 보인다.”고 밝히고 있다. 이는 이 사건에서 문제된 사내하청이 사실상 원청으로부터의 경제적 독립성이 없다는 점을 지적함으로써 원청이 사내하청 근로자들의 근로조건에 대해 실질적 지배력을 가진다는 점을 보다 적극적으로 뒷받침할 수 있는 하나의 징표로 제시하고자 한 것이라고 보인다.

6) 서울행정법원 2025. 10. 30. 선고 2024구합72896 판결

(1) 판결 내용

백화점면세점판매서비스노동조합(이하 “이 사건 노조”)은 백화점, 면세점, 복합쇼핑몰 등에 입점한 업체에서 일하는 판매·서비스직 직원들로 조직되어 있고, 이 사건 원고 조합원들은 백화점·면세점(이하 “이 사건 백화점·면세점”)에서 일하지만, 이 사건 입점업체와 근로계약을 체결한다. 이 사건 노조는 이 사건 백화점·면세점을 상대로 백화점·면세점의 영업시간 변경에 따른 근무시간 및 휴일 결정(제1 의제), 감정노동자 보호를 위한 고객응대매뉴얼 작성(제2 의제), 휴게실, 화장실 등 점포 내 시설물 이용 보장 및 개선(제3 의제)에 대한 교섭을 요구했다. 이 사건 노조는 근로시간, 근로환경 등 조합원의 노동조건을 입점업체 사용자가 전적으로 결정할 수 없고, 이 사건 백화점·면세점의 각종 지침을 따르고 이들의 관리·감독·평가를 받아야 하는 것이 현실이므로 이 사건 입점업체 사용자와의 교섭만으로는 조합원의 노동조건을 개선시킬 수 없어 반드시 이 사건 백화점·면세점과 교섭해야 한다고 주장했다. 그러나 이 사건 백화점·면세점은 교섭 의무가 없다고 주장하며 교섭을 거부했고, 이 사건 노조는 교섭 거부에 대한 부당노동행위구제신청을 했는데 서울지방노동위원회는 구제신청을 기각했고, 중앙노동위원회도 초심 판정을 유지했다. 그러나 서울행정법원은 재심판정을 취소하며 이 사건 백화점·면세점의 교섭 의무를 인정했다.

서울행정법원은 “이 사건 백화점·면세점이 교섭 의제와 연관된 노조 조합원들의 일부 근로조건에 관한 실질적 지배력을 직접 가지거나, 일부 근로조건에 관해서는 최소한 원사업주인 입점업체와 중첩적으로 가진다고 봄이 타당하다.”라고 하면서 “이 사건 백화점·면세점은 교섭 의제에 관해 노동조합법상 사용자로서 단체교섭 의무를 부담한다.”라고 판단했다.

한편, 이 사건 백화점·면세점과 입점업체가 체결한 계약은 도급계약이 아니라 ‘상품 매입거래계약’, 즉, 백화점·면세점은 입점업체로부터 상품을 공급받고, 입점업체는 백화점·면세점 내 입점업체별 매장에서 상품을 판매하는 계약이었다. 이와 관련하여 서울행정법원은 “상품 매입거래 계약에 임대차계약의 성격이 혼합돼 있음을 충분히 고려하더라도 백화

점·면세점이 영위하는 사업은 기본적으로 참가인 백화점·면세점 내에서의 ‘상품판매’에 해당함은 명백하고, 이는 판매사원들이 개별적인 상품 판매 업무를 수행함으로써 이루어지는 것”이라고 하면서 “판매사원들이 상품판매 업무에 관해 제공하는 노무는 백화점·면세점의 사업 수행에 상시적·필수적인 것은 물론 구조적으로 백화점·면세점의 사업체계에 직접 편입돼 있다고 충분히 인정할 수 있다.”라고 판시했다. 판단의 주요 근거는 다음과 같다.

- ① 백화점·면세점 내의 근로자들 중 직접 고용한 근로자들의 비중은 대략 5~20% 남짓이고 절대다수는 파견된 판매사원임. 입점업체별로 고유의 상품 특성을 고려한 독자적인 상품 판매전략을 수립·실행하여 매출이 극대화될 수 있도록 하기 위한 측면도 있다고 보임. 따라서 판매사원들이 상품판매 업무에 관하여 제공하는 노무는 이 사건 백화점·면세점의 사업 수행에 상시적·필수적인 것은 물론 구조적으로 이 사건 백화점·면세점 사업체계에 직접 편입되어 있다고 충분히 인정할 수 있음.
- ② 제1 의제: 이 사건 백화점·면세점이 이 사건 입점업체별로 근무일정표 등을 작성하는 데에 직접 관여하는 등의 강력한 영향력을 행사한다고 볼 자료는 없음. 그러나 백화점·면세점의 영업일, 영업시간 지정·변경이 원고 조합원 근로자들의 근무일과 근무시간에 일정한 영향을 미친다는 것 자체를 부인할 수 없음은 분명함. 조합원 근로자들 중 누군가는 이 사건 백화점·면세점의 영업일로 지정된 날에 반드시 노무를 제공해야 하고, 근로자 개인의 입장에서라도 백화점·면세점의 영업일에 맞추어 설정되는 근무일정표에 따라 자유로운 휴가 사용이나 휴식일 선택이 제한될 여지가 있으며, 교대제 근무나 시차제 근무의 조별·개인별 시업시간과 종업시간, 휴식시간도 백화점·면세점의 영업시간의 범위 내에서 결정되기 때문임.
- ③ 제2 의제: 판매사원들이 고객 응대 과정에서 겪을 수 있는 위험은 단순히 상품에 관한 불만 등의 유형으로만 한정되지 않고, 폭언, 폭행 등의 위협으로 물리적인 보호 조치가 필요한 경우나, 개별 매

장과 관계된 불만이 아니어서 백화점·면세점 측의 직접적인 대응이 필요한 경우 등을 얼마든지 상정할 수 있음. 이러한 경우에는 기본적으로 이 사건 입점업체별로 마련된 고객응대매뉴얼만으로는 판매사원들에 대한 보호가 충분히 이루어지지 않을 여지가 크고, 백화점·면세점 내에 배치된 보안요원, 현장 관리자, 각종 시설과 장비 등을 통하여 대응이 이루어질 필요성이 인정되며, 그 내용을 포괄할 수 있는 매뉴얼의 마련 주체는 이 사건 입점업체가 아닌 이 사건 백화점·면세점이 될 수밖에 없음.

- ④ 제 3의제: 백화점·면세점 내의 시설 관리에 관한 사항은 이 사건 입점업체가 아닌 이 사건 백화점·면세점이 지배·결정하는 영역에 있음이 분명함. 공항면세점의 경우에도 그 시설 일부를 임차하여 면세점 매장으로 활용하는 범위 내에서는 독립적인 휴게 공간 마련, 복지후생을 위한 기물 구비 및 품질 향상 등과 같이 시설 관리와 개선을 독자적으로 실행할 여지가 있으므로, 이에 관하여 이용·보장·개선을 요구하는 범위에서는 이 사건 면세점의 실질적 지배력이 충분히 인정될 수 있음.

(2) 특징 및 시사점

이 사건에서는 기존에 자주 문제되었던 도급계약에 근거한 원하청관계와는 달리 상품매입거래계약에 근거한 백화점·면세점과 입점업체 소속 근로자로 조직된 노조 간의 관계가 문제되었다는 특징이 있다. 사용자성 판단에서는 원청(계약외의 사용자)과 하청(계약상 사용자)간의 관계가 중요한 것이 아니라 원청이 근로자들에게 실질적 지배력을 미치고 있는지 여부가 중요한 것이라는 점을 확인하였다는 의의가 있다.

각 의제별 교섭대상 여부를 판단함에 있어 백화점·면세점측은 자신들은 사용자가 아니라 시설관리자임을 주장했지만 백화점·면세점 사업의 사업 수행에 상시적·필수적이며 이 사건 조합원들이 사업체계에 편입되어 있다는 점을 사용자성 인정의 근거로 삼았다. 또한, 고객의 개별 상품에 대한 불만사항 처리에 그치는 정도가 아니라 고객의 다양한 위협으로부터 근로자를 보호하기 위한 매뉴얼을 마련하고 백화점·면세점 내의

휴게 공간을 마련하는 등의 사항은 백화점·면세점이라는 사업장의 특성상 백화점·면세점의 통제 하에 있는 사항일 수 밖에 없고 백화점·면세점과의 교섭 없이 입점업체의 결정만으로는 해결할 수 없는 사항임이 분명함을 확인했다는 점에서도 의의가 있다. 이는 해당 사업과 근로자들의 업무가 수행되는 근무공간의 특성을 고려한 것으로 보이는데 사내하청에서의 산업안전보건 관련 사항을 원청과의 교섭 없이 해결하기 어려운 한계가 있다는 점이 고려되었던 기존 판결 입장과도 유사한 측면이 있다.

7) 서울남부지방법원 2007. 12. 10.자 2007카합2731 결정

(1) 결정 내용

이 사건에서 피신청인들(피신청인들은 신청인과 사이에 단말기 유지보수 위임도급계약을 체결한 협력업체인 주식회사 K, 주식회사 L 등에 소속된 근로자들) 등의 이 사건 건물 등에서의 출입금지를 구하는 신청 부분에 대하여 피신청인들은, 신청인이 협력업체 근로자들의 근로조건을 결정함에 있어 실질적 지배력과 영향력을 가진 자로서 노조법상 단체교섭의무를 부담하는 지위에 있으므로, 적어도 피신청인들이 신청인과 사이에 단체교섭을 하거나 이를 요구·촉구하고자 하는 목적으로 출입하는 것은 허용되어야 한다고 주장했다.

이에 대해 서울남부지법은 “노조법 제81조 제3호에서는 사용자가 노동조합의 대표자 등과의 단체교섭을 정당한 이유 없이 거부하거나 해태하는 행위를 부당노동행위로 규정하고 있는바, 단체교섭에서의 사용자는 일반적으로 근로계약상의 사용자를 말하는 것이지만 위 조항이 단결권의 침해에 해당하는 일정한 행위를 부당노동행위로서 배제·시정하여 정상적인 노사관계를 회복할 것을 목적으로 하고 있는 점을 감안하면, 근로계약상 사용자 이외의 사업주도 근로계약상의 사용자와 직접 근로계약관계를 맺고 있는 근로자를 자기의 업무에 종사시키고, 그 근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 부분적이기는 하더라도 근로계약상의 사용자와 같이 볼 수 있을 정도로 현실적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 경우에는 그 한도 내에서 위 조항에서 정하는 ‘사

용자’에 해당한다고 할 것이다.”라고 판시했다. 이 결정에서 판단의 근거로 제시된 주요 사실은 다음과 같다.

- ① 신청인(원청)은 고객(증권사)으로부터 전산망 유지보수 요구를 접수받으면, 협력업체 근로자들에게 이를 처리할 것을 ‘업무협조’ 방식으로 요청하면서 그 작업 시각 및 내용을 정하여 통보하였고, 이 경우 그 작업시간을 야간 또는 휴일로 정하는 경우도 있었음.
- ② 신청인은 출장소 별로 업무량과 소속인원을 파악한 후 협력업체 근로자들에 대하여도 근무지를 이동시키거나, 담당고객 및 사이트를 지정·관리하도록 지침을 세운 바 있음.
- ③ 신청인은 연휴 및 당번근무조를 편성함에 있어서 협력업체의 근로자들을 포함시켜 왔으며, 당번근무를 마친 협력업체 근로자들은 내부전산망을 통하여 신청인의 팀장, 본부장, 전무이사에게 당번근무 결과를 보고함.
- ④ 협력업체의 근로자들은 신청인의 사옥 등에서 근무하고 있으며, 신청인으로부터 그 작업에 필요한 일체의 드라이버 등 공구와 케이블 등의 자재, 컴퓨터와 사무비품, 사무공간 등을 제공받음.
- ⑤ 신청인은 협력업체 근로자들의 서열이 없어 조직관리에 애로가 있다는 사유 등을 들어 협력업체 근로자들에 대하여도 신청인의 네트워크사업부 자체 지침에 기하여 사원, 대리, 과장 3단계의 직급 체계를 운영함과 아울러 일정 요건을 갖춘 경우에는 신청인 회사의 출장소 ‘출장소장’직에도 임명하기로 결정하고, 이에 따라 협력업체 근로자들에 대하여 신청인 네트워크사업부 명의로 출장소장, 과장, 대리의 직급을 발령함.
- ⑥ 매년 협력업체의 직원들에 대한 평가를 실시하여 그 용역단가 등 승급 여부를 직접 결정함.
- ⑦ 신청인이 협력업체 근로자들에 대하여 그 작업 내용·시간을 구체적으로 지정하고, 공구, 자재, 사무용품 등을 지급하여 왔으며, 피신청인들은 이 사건 건물 등을 비롯하여 신청인의 사옥의 식당, 주차장 등 부대시설을 사용함.

- ⑧ 노동부는 신청인과 협력업체와의 사이의 위임도급계약은 불법과건 근로관계에 해당한다고 판단함.

(2) 특징 및 시사점

이 결정에서는 근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 부분적으로라도 사용자성 인정이 가능하다는 점을 확인할 수 있다. 다만, 이 사건의 경우 원청이 하청근로자들의 근로조건을 직접 결정하고 인사관리, 업무지시 등을 구체적으로 했다는 점, 특히 노동부가 원청과 하청간에 체결된 도급계약을 불법과건근로관계로 인정했다는 점 등을 통해 원청의 노동법상 사용자성을 용이하게 인정할 수 있는 사건이었다는 특징이 있다.

8) 대전지방법원 2011. 10. 6.자 2011카합782 결정

(1) 결정 내용

이 사건에서 채권자(하청노조)는 공공 및 사회서비스 업종에 종사하는 근로자들을 조직대상으로 하여 설립된 전국단위 산업별 노동조합이고, 채무자(원청)는 아태산업개발 주식회사와 청소 및 시설관리 도급계약을 체결하였는데, 아태산업개발과 근로계약을 체결한 청소용역 근로자들이 채무자 사업장에서 근무하고 있고 그 중 일부가 채권자에 가입하여 채권자 대전지역일반지부 수자원공사지회로 편성되었다. 채권자는 2011. 3. 28.부터 수차례에 걸쳐 채무자에 대하여 단체교섭을 요구하여 왔으나, 채무자는 이에 응하지 않았다. 대전지법은 “단체교섭의 당사자로서의 사용자로 함은 근로계약관계의 당사자로서의 사용자에 한정하지 않고 비록 근로계약관계의 당사자가 아니라고 하더라도 단체교섭의 대상이 되는 근로조건에 관한 사항의 전부 또는 일부에 관하여 그 근로자를 고용한 사업주로서의 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도로 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있으면 단체교섭의 당사자로서의 사용자에 해당한다고 볼 것이다.”라고 실시했고, 판단 근거로 인정된 사실관계는 다음과 같다.

- ① 채무자가 아태산업개발과 청소 및 시설관리 도급계약을 체결하면서 약정한 시설관리 및 청소용역 계약특수조건에 명시된 내용에 따르면 (1) 채무자는 용역에 관한 제반사항을 감독하고 관리하며 본 용역전반에 대해 포괄적으로 지시할 수 있는 권한을 가진 감독원을 지정할 수 있고, 감독원은 용역 업무전반에 대하여 점검 평가를 할 수 있으며, 평가결과에 따라 시정지시, 상벌 요구 등 필요한 조치를 취할 수 있음. (2) 채무자는 아태산업개발의 종업원에 대한 인원배치에 조정이 필요하다고 인정될 때에는 아태산업개발에게 배치조정을 요구할 수 있으며 아태산업개발은 상당한 이유가 없는 한 이에 응하여야 하고, 아태산업개발의 종업원 중 부적격 또는 부적당하다고 인정되는 자가 있을 경우 아태산업개발에게 그 사유를 통보하고 교체 등 조치를 요구할 수 있으며 아태산업개발은 지체 없이 이에 응하여야 함. (3) 아태산업개발은 용역원의 휴가시작 2일 전 사유, 기간 등을 기재한 소정 양식을 감독원에게 제출하여야 하며, 각 분야별로 용역업무 수행에 지장이 발생할 수 있다고 감독원이 판단 시 휴가자 수를 제한할 수 있고, 채무자는 아태산업개발과 협의하여 정원 및 근무인원을 가감조정 할 수 있음. (4) 폐지 등 재활용품은 분리수거하여 채무자가 지정하는 장소에 별도 보관하고 채무자의 지시에 따라 처리하여야 하고, 발생 수익금은 채무자의 자산으로 귀속되며, 채무자가 필요하다고 판단할 경우 아태산업개발의 용역업무수행 성과에 따른 용역원의 포상비, 복리후생비로 집행할 수 있고, 아태산업개발이 계약이행을 위하여 건물 내에서 사용하는 사무실, 탈의실, 창고, 전력 및 용수 등은 채무자가 제공 함. (5) 채무자는 아태산업개발에게 회사 외부지역의 물품운반, 행사지원 등을 위해 작업을 지시할 수 있고, 이때 공사의 평사원에 준하여 실비의 여비를 채무자가 사후 아태산업개발에게 정산 지급 하되 필요시 아태산업개발의 종업원에게 직접 지급할 수 있음.
- ② 실제로도 채무자는 감독원을 통해 채무자 사업장에서 근무하는 아태산업개발 소속 근로자들의 업무수행상태를 점검하고 있고, 채무자의 직원이 배석한 가운데 청소용역원이 폐지 및 고철을 매각하

여 그 매각대금을 사용하는 것에 관한 논의를 하였으며, 아태산업개발과 그 소속 근로자들 사이의 근로조건 등에 관한 지방노동위원회 조정사건에 참고인으로 참석하여 협의를 하기도 하였고, 아태산업개발에게 청소용역원의 감축을 요청하기도 하였으며, 아태산업개발에 대한 작업요청서 등을 통하여 아태산업개발 소속 근로자들의 작업 일시, 작업 시간, 작업 장소, 작업 내용에 등에 관하여 실질적·구체적인 결정을 하였고, 아태산업개발 소속 근로자들을 위한 지하휴게시설에 TV케이블 및 전화케이블, 개인옷장, 냉장고 등을 설치하여 주기도 하였음.

또한, 대전지법은 “위와 같이 채무자가 감독원을 통해 채무자 사업장에 근무하는 아태산업개발 소속 근로자들에 대하여 구체적인 업무지시 및 업무감독을 하고 있고, 위 근로자들의 근로조건을 실질적으로 결정하고 있는 점 등을 고려하면, 채무자는 위 아태산업개발 소속 근로자들에 대하여 적어도 폐지처분, 휴게공간 개선, 노동조합 사무실 제공, 연장근로 조정, 업무범위 조정에 관하여는 아태산업개발의 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도로 실질적이면서 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있다고 봄이 상당”하다고 설시했다. 다만, 채무자가 단체교섭의 당사자로서의 사용자에게 해당한다고 하더라도 직접고용관계가 없는 아태산업개발 소속 근로자들에 대한 관계에서 임금, 정년 등의 직접고용과 관련된 사항은 단체교섭의무의 대상이 되지 않는다고 판단했다.

(2) 특징 및 시사점

이 사건에서 법원은 교섭의제별로 원청이 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는지 여부를 판단했고, 용역계약서에서 용역 전반에 대한 원청의 지시 권한과 용역업체 근로자에 대한 인사관리, 업무감독 등에 관한 구체적인 내용들을 명시하고 있을뿐 아니라 실제로도 원청이 용역업체 근로자에 대한 업무내용, 근로시간 및 장소 등을 정하고 근로조건에 관여했다는 점 등을 통해 노조법상 사용자성을 인정했다.

2. 개정 노조법 제2조 제1호 후단의 해석 원칙

위 1.에서 살펴본 일련의 판례들과 같이 이미 오래전부터 법원은 사용자를 근로계약을 체결한 사업주만으로 국한하지 않고 노동3권의 실질적 보장이라는 측면에서 사용자를 확인·판단하여 왔다. 그리고 2025년 9월 9일 노조법을 개정해 “사업주, 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자” 이외에 “근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 그 범위에 있어서는 사용자로 본다.”라는 후단 규정을 신설하였다. 개정법은 2026년 3월 10일 시행될 예정인 바, 노조법 제2조 제2호 신설 후단에 대한 해석이 요청된다. 이하에서는 1.에서 검토한 판례들을 기본으로 하면서 먼저 노조법 제2조 제2호 신설 후단의 사용자 개념 해석의 방향에 관해 살펴보고, 다음으로 사용자 개념을 해석할 때의 판단 기준에 대하여 논해보고자 한다.

1) 기본원칙 : 헌법상 노동3권 보장

노조법상 사용자성 판단의 기본원칙으로서 가장 중요한 점은 헌법상 기본권인 단체교섭권의 구체적 실현이라는 관점이 중심에 있어야 한다는 점이다. 특히 사용자는 노무제공관계의 실질에 비추어 노동3권을 침해할 수 있는 권한·지위를 가지고 있는가라는 점이 중요하고, 사내하청 업체 근로자들의 노동조건 등을 원청과의 단체교섭에 의해 집단적으로 결정할 필요성과 타당성이 있는지라는 관점에서 판단되어야 한다.

노동3권은 법률이 없더라도 헌법의 규정만으로 직접 법규범으로서 효력을 발휘할 수 있는 구체적 권리이다.⁹⁾ 우리나라 헌법학에서 노동3권은 법률상 규정이 없더라도 그 성질상 사인(私人) 간에도 직접 적용되는 권리라고 보는 학설이 지배적이고,¹⁰⁾ 노동3권의 직접적 효력을 인정하

9) 대법원 2020. 9. 3. 선고 2016두32992 전원합의체 판결.

10) 김철수, 『헌법학개론』, 박영사, 1992, 274쪽, 김선택, “사법질서에 있어서의 기본권 효력”, 『고려법학』 제39권 제39호, 2002, 170쪽, 장영수, 『헌법학』,

는 견해에 따르면, 노동3권은 단체협약 체결을 둘러싼 사용자와 근로자 사이의 관계를 그 규율대상으로 하는 것으로서 양자 간의 법률 관계가 사법(私法)적인 성격임이 명백하므로 직접적 효력을 가진다고 인정해야 한다.¹¹⁾ 노동3권은 원래부터 태생적으로 사인과 사인 간의 행위를 전제로 한 것이고 사용자나 그 밖의 사인이 근로자의 단결활동을 방해하거나 억압하도록 방지하면 무의미하게 되는 성질의 기본권이므로 사인 간의 관계에 대하여도 직접 효력을 미친다고 보아야 한다는 입장에서 노동3권의 대사인적 효력은 직접적 효력이 인정된다.

노조법과 같은 법률이 없다 하더라도 사인(私人) 간에 직접적 효력을 갖는 노동3권의 의의가 사용자성 판단의 기본 원칙이 되어야 한다. 서울고등법원 2024. 1. 24. 선고 2023누34646 판결이 실시한 바와 같이 “헌법상 기본권인 단체교섭권을 구체적으로 실현하는 관점”과 “노무제공관계의 실질에 비추어 노동3권을 침해할 수 있는 권한·지위에 있는지의 관점”이 노조법상 사용자성 판단의 출발점이 되어야 할 것이다.

또한 2025. 7. 25. 내려진 서울행정법원 판결들(2022구합69230, 2023구합55658·56231)에서 제시된 “사내하청업체 근로자들의 노동조건 등을 원청과의 단체교섭에 의해 집단적으로 결정할 필요성과 타당성이 있는지 여부”라는 판단 기준 역시 헌법상 노동3권 보장의 관점에서 도출되는 기준이라고 볼 수 있을 것이다.

2) “근로계약 체결의 당사자가 아니더라도”

원하청 노동관계에서 원청 사업주 이외에 다면적 노동관계에서의 다수사용자도 존재할 수 있다는 점에 대한 고려가 필요하다. 사용자 범위는 원하청 노동관계에서만 아니라 플랫폼 노동관계 등 다면적 노동관계에서 노동조건에 대한 실질적·구체적 지배·결정권을 갖고 있는 사람

홍문사, 2021, 503쪽, 전광석, 『한국헌법론』, 집현재, 2018, 962쪽 등. 각 학자들의 견해에 관한 보다 상세한 내용은 심현우, 『기본권 대사인적 효력에 대한 직접효력설의 적정성 검토』, 고려대학교 석사학위 논문, 2022, 83~84쪽 참조.

11) 김선택, 위의 글, 170쪽, 장영수, 위의 글, 503쪽, 전광석, 위의 글, 962쪽.

의 사용자성을 확인하는 의미를 가진다.

특히 ‘근로계약 체결의 당사자가 아니더라도’ 사용자인 바, 이것의 의미는 두 가지로 해석될 수 있다. 첫째, 근로계약 체결 당사자가 아닌 위임·도급계약 등 근로계약 이외의 노무제공계약을 체결한 상대방도 사용자가 될 수 있다는 것. 둘째, 직접적인 노무제공계약이 존재하지 않더라도 사용자가 될 수 있다는 것. 특히 첫 번째 의미에서 개정 노조법 제2조 제2호 후단 신설 규정은 근로기준법상 근로자 이외에 특수고용노동자 등 근로기준법상 근로계약 이외의 노무제공계약을 체결하고 있는 사람들에게 대한 사용자 책임을 포괄적으로 규정한 것으로 해석할 수 있다. 두 번째 의미에서 개정 노조법 제2조 제2호 후단 신설 규정은 특히 원하청 노동관계상 원청의 사용자성을 인정한 것으로 해석할 수 있음은 물론이고, 다면적 노동관계상 다수 사용자의 가능성을 인정한 것으로도 해석할 수 있을 것이다.

따라서, 위 규정의 시행 이후 집단적 노동관계상 사용자는 ① 근로계약관계상 사용자, ② 노무제공관계상 사용자(들), ③ 직접적 계약관계가 존재하지 않는 사용자(들) 등으로 구성될 수 있다.

3) “근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자”

위 2)의 ①-③과 같은 사용자가 존재할 수 있다 하더라도 집단적 노동관계상 사용자로서 사용자는 “근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자”일 것이 요구된다. 여기에서 (1) ‘근로조건’, (2) ‘실질적이고 구체적’, (3) ‘지배·결정할 수 있는 지위’의 의미에 대한 해석이 요구된다.

(1) 근로조건

우선, 여기에서 근로조건은 근로계약상 근로조건만을 의미하는 것은 아닐 것이다. 노무제공계약이 존재하는 경우에는 해당 계약상 노동조건, 노무제공계약이 존재하지 않는 경우에는 노무제공관계상 성립할 수 있

는 노동조건을 의미한다고 볼 수 있다.

개정 노동조합법 제2조 제5호 ‘노동쟁의’의 개념상 변화에 따라, 노동쟁의에는 “임금·근로시간·복지·해고·근로자의 지위 기타 대우 등 근로조건에의 결정”과 “근로조건에 영향을 미치는 사업경영상의 결정”이 포함되는 바, 제2호가 규정한 ‘근로조건’ 또한 노동쟁의가 성립할 수 있는 범위에서 결정될 수 있다고 해석된다.

해당 개념들은 통상적으로 근로기준법상 근로조건에의 개념적 요소들을 1차적으로 고려할 수 있지만, 근로기준법상 근로자 이외의 노조법상 근로자와 관련하여서는 노동관계상 보수, 노동의 시간과 휴식시간, (유급) 휴일, 복지제도, 노동계약의 종료, 노동계약상 지위(고용승계 등), 기타 대우 등이 포함될 수 있을 것이다. 산업안전 및 보건에 관한 문제도 ‘기타 대우’에 포함되는 것으로서 근로조건에 해당한다고 볼 것이다. 또한 기존 헌법재판소 결정에서는 산업재해를 입은 근로자에 대한 보상을 어떻게 할 것인가의 문제도 근로조건에 관한 기준의 한 문제로 볼 수 있다고 판단한바 있다.¹²⁾

플랫폼 노동관계에서의 알고리즘 또한 근로조건에 포함될 여지가 있다. 플랫폼 노동관계상 알고리즘은 기존의 노동관계에서 사용자가 가시적 수단으로 노동을 지휘통제하는 수단이 비가시화(알고리즘화)된 것으로 평가할 수 있는 바, 이것을 임금의 결정에 관한 사항, 표창과 제재에 관한 사항, 노동자 전체에 적용될 사항 등 사실상 일반 근로자의 취업규칙상 필수적 기재사항으로서 근로조건에 포함되는 것으로 평가할 수 있다는 것이다. 특히 알고리즘 변경은 ‘사업경영상의 결정’으로서 노동쟁의 대상 범주에도 포함될 가능성이 있다. 보수에 영향을 미치는 알고리즘 변경 등 노동조건에의 변화와 밀접한 연관성을 갖는 알고리즘은 그 자체를 근로조건에의 한 내용으로 해석될 수도 있지만, 그 알고리즘을 변경하는 것은 사업경영상의 결정으로서 포함될 수 있다고 볼 수 있다.

한편, 제2조 제2호가 규정한 ‘근로조건’은 개별적 노동관계에서의 근로조건으로만 국한될 수는 없고, 집단적 노동관계에 관한 사항도 포함시켜야 할 것이다.

12) 헌법재판소 1996. 8. 29. 선고 95헌바36 전원재판부 결정.

(2) “실질적이고 구체적인 지배·결정”

‘실질적이고 구체적인 지배·결정’은 노동조건에 대한 결정적 권한, 책임, 영향력을 갖는 경우를 의미한다고 해석할 수 있을 것이다. 지배·개입의 부당노동행위에 대한 법원 판결례에서는 “근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 그 근로자를 고용한 사업주로서의 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도”를 “실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위”로 인정하였다.¹³⁾

특히 원하청관계에서는 “개별도급계약을 통하여 사내 하청업체 근로자들의 기본적인 노동조건 등에 관하여 고용사업주인 사내 하청업체의 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도로 실질적이면서 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있고 사내 하청업체의 사업폐지를 유도하는 행위와 그로 인하여 사내 하청업체 노동조합의 활동을 위축시키거나 침해하는 지배·개입 행위를 하였다면” 사용자로서의 책임을 인정한다.¹⁴⁾

그런데 법 개정제안 이유문에서는 “다면적 노무제공관계가 확산되고 있는 상황에서 실질적으로 근로조건에 대한 지배력을 행사하는 사용자는 형식적인 계약관계의 부존재를 이유로 단체교섭 등의 사용자로서 책임을 회피하고, 근로계약을 체결한 사용자는 근로조건을 개선할 권한과 능력이 없어 근로자들의 노동3권이 사실상 형해화되는 결과를 초래하고 있음.”이라고 표현하고 있다.

앞서 살펴본 서울고등법원 판결(2023누34646 판결)에서는 “노동조합 법상 단체교섭의무를 부담하는 사용자에게 해당하는지 여부는 기본적으로 헌법상 기본권인 단체교섭권을 구체적으로 실현하는 관점에서 파악하여야 할 것인데, 단체교섭의 대상인 근로조건 등을 지배·결정하는 자와 단체교섭이 이루어지지 않는다면 사용자와 대등한 지위에서 집단적 교섭을 통해 근로조건 등을 결정·개선할 수 있도록 하는 단체교섭권이 실질적으로 기능하지 못하게 된다.”, “노무제공관계의 실질에 비추어 노동3권을 보장할 필요성이 있는지를 주요 판단요소로 고려하는 노동조합법

13) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2007두8881 판결.

14) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2007두8881 판결.

상 근로자 개념의 해석에 조응하여(대법원 2018. 6. 15. 선고 2014두 12598, 12604 판결 등 참조) 노동조합법상 사용자 여부 또한 노무제공관계의 실질에 비추어 노동3권을 침해할 수 있는 권한·지위에 있는지의 관점에서 파악하여야 한다.”라고 한다.

법 개정 취지와 단체교섭의 부당노동행위에 대한 고등법원 판결 내용을 고려했을 때, ‘실질적이고 구체적인 지배·결정’은 2010년 지배개입의 부당노동행위에 대한 대법원 판결이 원하청 노동관계에서 사용자성을 인정한 경우보다 넓게 해석될 필요가 있다. 또한 위 2023누34646 판결에서 제시한 ‘실질적이고 구체적인 지배·결정’ 기준은 노조법 제2조 제2호 개정 전 원청의 사용자성 판단을 위한 기준이었으므로, 반드시 여기에 얽매일 필요도 없다고도 볼 수 있다.

한편, 다수 사용자관계에서 사용자의 노동조건에 대한 지배결정권은 기능적으로 구분·분리될 수 있고, 특정 노동조건에 대한 지배결정권이 다른 노동조건에 대한 지배결정권을 의미하는 것은 아닐 수 있다. 따라서 ‘실질적이고 구체적인 지배·결정’은 모든 사안에 대한 종합적인 ‘실질적이고 구체적인 지배·결정’이 아니라 개별 노동조건에 따라 다르게 판단될 수 있는 바, 단체교섭의 대상인 노동조건 등을 지배·결정하는 자의 의미로서 개별적으로 판단될 필요가 있을 것이다. 이는 결국 단체교섭 의제에 따라 결정될 문제라고도 볼 수 있다. 단체교섭 의제에 따라 복수의 사용자가 노동조건에 대한 ‘실질적이고 구체적인 지배·결정’력을 동시에 행사할 수 있는 경우, 동일한 노동조건에 대하여 복수의 사용자가 존재할 수 있을 것이다. 예컨대 동일한 프로그램을 사용하는 복수의 대리운전업체 소속 대리운전노동자가 해당 프로그램 관련 노동조건에 대한 단체교섭을 요구하는 경우 등을 생각할 수 있다.

‘실질’과 ‘구체’ 용어에 대한 해석과 관련한 논란도 예상된다. ① 지배·결정권의 ‘실질성’은 근로자의 노동조건을 실제 결정할 능력을 갖고 있다는 의미일 것이고, ② 지배·결정권의 ‘구체성’은 근로자의 노동조건을 구체적으로 결정하고 있다는 의미일 것인데, 이 양자는 각각 별개로 적용되는 개념이라기 보다는 근로자의 노동조건을 실제 결정할 수 있으면서 구체적으로 결정하고 있음을 의미하는 것으로 충분하다.

특히 지배의 개념과 관련하여서는 “‘사전적(事前的) 행위 제어’와 ‘자의적 개입 권능’이 결합된 것으로, 타인의 행위에 대해서 구체적이거나 직접적인 지시를 매개하지 않고서도 의도하는 행위를 강제할 수 있고, 의도에서 벗어나는 경우에는 언제라도 개입하고 수정하고 제재할 수 있는 권한이 유보되어 있을 때를 의미하며, 예컨대, 원청이 목표를 사전에 설정하고 그 성과 여부를 평가해서 재계약 여부를 결정하거나, 제3자를 통해 노동과정을 제어하면서 필요한 경우 제3자를 교체하는 방식으로 원하는 조직 관리를 실현하거나, 원청의 이익 실현에 최적화된 구조를 만들어 놓음으로써 그 구조 안에 들어오는 자는 자신의 의지와 상관없이 구조적으로 원청의 이익에 복무되도록 하는 것이며, 이러한 지배는 직접적일 수도 있고 간접적·유보적일 수도 있는데 간접적 지배가 사내 하청에 좀 더 잘 대응할 것”이라는 견해가 있다.¹⁵⁾ 이러한 견해는 타당하다고 생각되고, 요컨대 ‘지배’는 직접적인 지시나 결정보다 폭넓은 개입, 관여, 통제를 의미하는 개념으로 이해할 수 있을 것이다.

(3) “~할 수 있는 지위에 있는 자”

‘실질적이고 구체적인 지배·결정’은 ‘가능성’으로 충분한가, ‘현재성’이 요구되는가도 문제될 수 있다. ‘실질적이고 구체적인 지배·결정’을 지배·결정의 가능성을 갖고 있는 정도가 아니라, 현실적으로 근로조건에 대한 지배·결정권이 행사되고 있음을 의미하는 것으로 볼 것인지의 문제이다. 다시 말해, ‘실질적이고 구체적인 지배·결정’은 노동조건에 대한 지배·결정의 ‘현재성’을 요구하는 것으로 해석할 것인지, 아니면 지배·결정의 가능성으로도 충분하다고 볼 것인지에 대한 해석상 논란을 예상해볼 수 있다.

현재 문언이 “근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자”이므로, ‘가능성’을 의미하는 것으로 해석해야 한다고 생각한다. 특히 단채교섭권 보장은 “장차 발생할 수 있는 노동조건의 저하”를 막기 위한 목적도 있으므로(5호 개정을 통해 이 목적이 보

15) 박제성, “사내하청의 담론과 해석”, 『노동법연구』 제40호, 서울대학교 노동법연구회, 2016, 127쪽.

다 강조되었다고 볼 수 있음), 장래 발생할 수 있는 노동조건 등을 단체교섭 의제로 삼는 것도 가능하고, 따라서 현재 실현되지 않은 근로조건도 2호의 근로조건에 포함된다고 해석하는 것이 법 정합적 해석일 것이다.

(4) 근로자 개념과의 관계

한편, ‘실질적이고 구체적인 지배·결정’이 노동조합법상 근로자성 판단 기준으로서 요구되는 “노무제공관계의 실질에 비추어 노동3권을 보장할 필요성이 있는지”와 동일한 것인지 아닌지 판단이 요구된다.

통상적으로 사용자개념 확장은 ‘원청 = 하청근로자의 노조법상 “사용자” 가능’과 ‘하청노동자 ≠ 원청의 노조법상 “근로자”’의 구조로 이해될 수 있다. 만약 하청근로자에 대한 원청의 사용자성 인정으로 인해 노동조합법상 근로자성이 인정되는 것으로 보게 되면, 현행 노동조합법 체계상 극복하기 어려운 문제들이 발생할 수 있다(‘종사근로자’ 개념, 교섭창구단일화 문제 등).

특히 2호는 “그 범위에 있어서는 사용자로 본다.”라고 하고 있으므로, “근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자”는 “실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위”에 있는 영역의 근로조건에 대한 집단적 노동관계상 사용자로서 지위를 갖는 것이고, 사용자로서의 지위는 개별 근로자에 대한 사용자로서의 지위가 아닌, 집단적 노동관계상 노동조합과의 관계에서 단체교섭의무의 수규자, 쟁의행위 수인의무의 수규자, 부당노동행위금지제도의 수규자 등의 의미를 갖는다고 할 것이다.

3. 원하청 관계에서 사용자성 판단 기준

위 2. 1)에서 살펴본 해석의 기본 원칙을 적용하고자 할 때 노조법 제2조 제2호 신설 후단의 사용자를 판단하기 위한 기준을 특히 원하청관계를 중심으로 살펴보았을 때 다음과 같다.¹⁶⁾

¹⁶⁾ 이하의 내용은 ‘원하청관계’에서의 사용자 판단 기준을 정리하고자 한 것이므로, 원하청관계 이외 노조법 제2조 제2호 후단 사용자 개념 신설과 함께

1) 하청근로자의 근로조건에 대한 원청의 관여, 지배·결정

노조법 제2조 제2호 후단의 사용자 개념은 근로조건에 대한 지배 및 결정을 하는 경우에 성립되는 개념이므로 원청이 하청 근로자의 근로조건에 어느 정도 관여, 개입, 지배, 결정하는지가 주된 판단 기준이 될 수밖에 없다. 원청이 직접적으로 하청근로자 근로조건을 결정하는 경우만이 아니라 도급계약서, 과업지시서, 업무매뉴얼 등을 통해 지배·결정하는 경우도 포함될 수 있다.

2) 파견근로관계 판단 기준과 노조법상 사용자성 판단 기준의 관계 및 구분(하청 근로자들의 노무가 원청의 사업수행에서 상시적·필수적이고 사업체계에 편입되어 있는지 여부, 원청의 하청근로자들에 대한 지휘·명령)

법원이 제시한 판단기준 중 ‘하청근로자들의 노무가 원청의 사업수행에서 상시적·필수적인지’, ‘원청의 사업체계에의 편입되어 있는지’라는 기준은 원청과 하청근로자 간의 파견근로관계 해당 여부가 문제된 사건, 즉, 근로자파견과 도급의 구분이 문제된 사건에서 제시된 판단기준이기도 하다.

즉, 대법원 2015. 2. 26. 선고 2010다106436 판결 등¹⁷⁾에서 제시된 근로자파견 판단기준은 ① 근로자파견에 해당하는지는 당사자가 붙인 계약의 명칭이나 형식에 구애될 것이 아니라, ② 제3자(원청업체)가 당해 근로자(하청 근로자)에 대하여 직·간접적으로 그 업무수행 자체에 관한 구속력 있는 지시를 하는 등 상당한 지휘·명령을 하는지, ③ 당해 근로자가 제3자 소속 근로자와 하나의 작업집단으로 구성되어 직접 공동 작업을 하는 등 제3자의 사업에 실질적으로 편입되었다고 볼 수 있는지, ④ 원고용주(하청업체)가 작업에 투입될 근로자의 선발이나 근로자의

확장된 사용자의 범위 전체에 대한 기준은 아님에 유의할 필요가 있다.

17) 대법원 2016. 7. 22. 선고 2014다222794 판결, 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다211619 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016다240406 판결, 광주고등법원 2015. 4. 24. 선고 2012나4823 판결 등 다수

수, 교육 및 훈련, 작업·휴게시간, 휴가, 근무태도 점검 등에 관한 결정 권한을 독자적으로 행사하는지, ⑤ 계약의 목적이 구체적으로 범위가 한정된 업무의 이행으로 확정되고 당해 근로자가 맡은 업무가 제3자 소속 근로자의 업무와 구별되며 그러한 업무에 전문성·기술성이 있는지, ⑥ 원고용주가 계약의 목적을 달성하기 위하여 필요한 독립적 기업조직이나 설비를 갖추고 있는지 등이다.

불법파견 해당 여부가 문제된 사건에서 파견과 도급의 구분 기준 중 하나로 제시되었던 “당해 근로자가 제3자 소속 근로자와 하나의 작업집단으로 구성되어 직접 공동 작업을 하는 등 제3자의 사업에 실질적으로 편입되었다고 볼 수 있는지”에서 언급된 사업에의 “편입”이라는 개념은 우리나라 현행법에서 규정하고 있는 개념은 아니지만 독일 근로자파견법(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)에 규정되어 있는 개념이다. 독일 근로자파견법은 근로자파견의 개념에 대해 “근로자가 사용사업주의 노동조직에 편입되어 사용사업주의 지시에 따르는 경우”에 근로자는 근로하기 위해 파견된 것이라고 규정하고 있다(독일 근로자파견법 제1조 제1항 2문). 이 규정은 2017년 개정법에서 신설된 것으로 연방노동법원이 오랫동안 파견과 도급의 구별기준으로서 제시하였던 ‘사용사업주 조직에의 편입(Eingliederung)’ 및 ‘사용사업주의 지시(Weisungen)’라는 두 개념을 사용하여 규정한 것이다.¹⁸⁾

반면 우리나라의 현행 근로자파견법상 근로자파견 개념은 “사용사업주의 지휘·명령을 받아 사용사업주를 위한 근로에 종사하게 하는 것”이라고 하여 독일과 같이 ‘사업에의 편입’이라는 개념을 명시하고 있지 않음에도 불구하고 우리 대법원이 이를 근로자파견의 판단기준 중 하나로 채택한 것이다. 참고로 독일 연방노동법원 판례에서는 하청의 근로자가 원청의 사업 내에서 원청이 직접 고용한 근로자들과 혼재되어서 작업을 하거나 원청의 사업 내의 직접고용 근로자와 하나의 작업집단으로 구성되어 일하는 경우에는 하청의 근로자가 원청의 사업조직에 편입되었다고 인정될 가능성이 높다고 본다.¹⁹⁾ 또한 근로자가 종전까지 원청의 직

18) BAG 18.1.2012 - 7 AZR 723/23 등 다수.

19) BAG 30.1.1991 - 7 AZR 497/89.

접고용근로자에 의해 처리되던 업무를 수행하는 경우²⁰⁾에도 도급인의 사업조직에 편입되었다는 정황으로 인정될 수 있다고 한다. 또한, 연방노동법원은 하청의 근로자가 휴가, 근로시간, 산업안전 등의 보호를 원청이 아닌 하청으로부터 보장받는다고 하여 그로 인해 원청 사업에의 완전한 편입이 부정되는 것도 아니라고 한다.²¹⁾ ‘사업에의 편입’이라는 개념은 원칙적으로 하청 근로자에 의해 제공되는 노무가 원청의 사업에서 차지하는 중요성의 정도, 원청 사업내의 다른 노무와의 관련성의 정도를 통해 판단되어야 하는 것이라고 보아야 한다.²²⁾

한편, 법원이 제시한 노조법상 사용자성 판단기준 중 ‘하청근로자들의 노무가 원청의 사업수행에서 상시적·필수적인지’ 역시 근로자파견근로관계 판단에서 제시되는 판단 요소중 하나이다. 즉, 불법파견이 인정되었던 사건에서 대법원은 “사내협력업체 소속 근로자들이 담당한 엔진조립 업무는 피고(원청)의 필수적이고 상시적인 업무이며 피고가 정한 생산계획 등에 따라 일일작업량이 실질적으로 정하여져 있으므로 이 사건 사내협력업체가 이를 무시한 채 자체적으로 생산계획을 조절하는 것은 현실적으로 불가능해 보이고, 전체적으로 보아 피고가 계획한 전체 엔진 생산 일정 등에 연동하여 작업이 진행되지 않을 수 없다.”라고 판시한 바 있다.²³⁾

이와 같이 법원은 원청의 직접고용의무가 인정될 수 있는 근로자파견관계 판단에서 사용하는 일부 판단 기준을 노조법상 실질적 사용자성 판단에서 차용하고 있는바, 양자의 관계와 구분에 대해 유의할 필요가 있다. 원청과 하청근로자간의 관계가 불법파견관계로 인정된다면 직접고용의무가 있는 사용자, 즉, 개별적 노동관계에서의 사용자가 될 수 있으므로 노조법상 사용자성은 더 살펴볼 필요도 없이 당연히 인정될 것이다. 이 문제와 관련하여 김린 교수는 “개정법은 ‘불법파견’고용 책임이 아니더라도, 근로조건을 통제하면 ‘교섭 책임’을 부담한다는 것. 즉, 교

20) BAG 30.1.1991 - 7 AZR 497/89.

21) BAG 30.1.1991 - 7 AZR 497/89.

22) 박귀천, “근로자파견성’ 판단 기준 재정립의 모색 - 판례에 대한 분석을 중심으로”, 『노동법포럼』 제27호, 노동법이론실무학회, 2019, 62~63쪽.

23) 대법원 2021. 7. 8. 선고 2018다243935, 2018다243942(병합) 판결.

섭 책임 문턱은 고용책임보다 낮아야”한다고 하면서, 교섭 책임을 묻기 위해 불필요하게 ‘불법과건’에 준하는 엄격한 기준(업무 필수성 등) 입증을 요구할 가능성을 배제하기 어려운데 법 개정 취지의 축소 및 고용 책임과 교섭 책임 간의 분리 왜곡 우려, 불법과건 책임도 부담할 수 있다는 염려때문에 사용자가 원하청 교섭을 꺼리게 되는 요인으로 작용할 수 있다는 점을 지적한다.²⁴⁾

원청과 하청 근로자 간의 집단적 노동관계에서 문제되는 ‘실질적 지배·결정’이라는 기준은 그간 법원이 원청과 하청 근로자 간의 개별적 노동관계 사건에서 제시해 온 원청의 하청 근로자에 대한 상당한 지휘·명령 등의 판단 요소와는 구별되는 개념임을 유의해야 한다. 근로자과건법상 직접고용의무가 있는 원청으로 인정되지 못한다 하더라도 노조법상 사용자로는 인정될 수 있음을 의미하는 것이다. 이는 마치 노조법상 근로자라고 하여 반드시 근로기준법상 근로자로 인정되는 것은 아닌 것처럼 노조법상 사용자로서 하청 근로자에 대해 노조법상 의무를 부담하는 지위에 있다고 하여 근로기준법, 근로자과건법 등에서 문제되는 개별적 노동관계에서의 사용자라고 단정할 수는 없는 것과 유사하다.

위에서 살펴본 서울고등법원 2020. 8. 10. 선고 2020노115 판결(대법원 2021. 2. 4. 선고 2020도11559 판결)에서는 불법과건 해당 여부와 노조법상 사용자성 해당 여부가 모두 문제되었는데 불법과건 해당 여부를 판단함에 있어서는 원청이 하청근로자들에 대해 직·간접적으로 그 업무 수행 자체에 관한 구속력 있는 지시를 하는 등 상당한 지휘·명령을 하였는지 여부에 관하여 판단한 반면, 하청근로자에 대한 원청의 부당노동행위 주체로서의 사용자성, 즉, 노조법상 사용자성을 판단함에 있어서는 지휘·명령 여부에 대해 판단하지 아니하였다는 점은 양자는 일부 관련성은 있지만 구분되는 법리의 문제라는 점을 보여준다.

다만, 원청의 하청근로자에 대한 업무상 지시, 지휘·명령이 있었다는

24) 김린, “개정 노동조합법 제2조 시행의 쟁점과 과제—실질적 지배력, 입증책임, 교섭절차를 중심으로 —”, 『노동조합법 제2조 개정과 단체교섭의 새로운 지평-‘노란봉투법’ 이후의 과제-』, 한국고용노사관계학회 2025년 추계정책토론회 자료집, 2025. 10. 30., 5쪽.

사실을 원청의 노조법상 사용자성 인정의 하나의 판단 근거로 제시한 판결들도 있는데 이는 어떻게 보아야 할 것인가라는 의문이 제기된다. 생각건대 원청이 하청근로자에 대해 업무상 지휘·명령을 하였다는 사실이 인정된다면 원청의 하청근로자에 대한 노조법상 사용자성이 인정될 가능성이 높아지겠지만 그러한 사실이 없다고 하여 사용자성이 부정된다고 보아서는 안 될 것이다. 즉, 노조법상 사용자성 판단에서는 원청의 하청근로자에 대해 업무상 지휘·명령이 없다고 하여 사용자성을 부정하여서는 안 된다는 점을 유의할 필요가 있다. 노조법상 사용자성 판단에서는 “근로조건에 대한 지배·결정”이라는 점이 중요한 것이지, 개별적 근로관계의 특징인 지휘·감독에 의한 사용종속관계라는 점이 중요한 것은 아니기 때문이다.

3) 법률상 원청의 의무가 인정되는 사항

앞서 살펴본 바와 같이 법원은 산업안전보건, 임금에 대한 연대책임 등과 같이 법률상 원청의 의무로 규정되어 있는 사항이라도 원청과 하청노조 간의 단체교섭사항이 될 수 있다는 점을 인정한 바 있다. 더 나아가 법률상 원청의 의무로 규정되어 있는 사항에 대해서는 원청이 당연히 단체교섭 당사자로서의 지위에 있다고 볼 수도 있다.

4) 하청업체의 경제적 독립성

2023구합55658·2023구합56231 판결에서는 하청업체의 원청으로부터의 경제적 독립성이 판단 기준으로 제시되었다. 이 판결에서는 하청업체가 원청에 경제적으로 종속되어 있다는 점이 원청의 사용자성을 인정하는 하나의 근거가 되었다.

이 기준은 불법파견 해당 여부가 문제된 사안에서 대법원이 제시한 판단 기준인 “(하청이) 계약의 목적을 달성하기 위하여 필요한 독립적 기업조직이나 설비를 갖추고 있는지”와 유사한 판단 기준처럼 보인다. 대법원은 “비록 하청이 근로자들과의 고용계약에 따른 각종 인사처리를 행하고 독자적인 조직체계를 가지는 등 회사의 실체 내지 사업경영상

독립성을 갖추고 있다고 하더라도 이는 원청과 하청 근로자들 사이에 직접 고용관계를 인정할 수 없는 근거가 될 뿐 근로자파견인지 도급인지 여부를 판가름하는 기준은 될 수 없다”고 판시한 원심 판결을 지지하면서 결론적으로는 근로자파견을 인정한바 있다.²⁵⁾ 요컨대, 하청의 독립적 실체가 인정된다 하더라도 이 때문에 근로자파견관계가 부정되는 것은 아닌 것처럼 하청의 독립성이 원청의 노조법상 사용자성을 부정하는 판단기준으로 사용될 수는 없다.

5) 교섭의제별 사용자성 판단

법원은 노조법상 사용자성 판단의 기준을 실시한 후 해당 사건에서 문제된 교섭의제별로 판단하고 있다. 노조가 사용자에게 교섭을 요구할 때 처음에는 구체적인 교섭의제를 특정하지 않은 채 교섭 요구를 하더라도 결국 구체적 교섭의제별로 의무적 교섭 사항에 해당되는지 여부를 판단하게 될 것이다.

하청 근로자에 대한 원청의 사용자성은 근로조건에 대해 실질적·구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자가 그 범위에 있어서 사용자가 되는 것이기 때문에 문제되는 근로조건별로 사용자로서의 의무를 부담해야 하는지 아닌지를 판단할 수밖에 없을 것이다.

이러한 판단구조는 하청노조 입장에서는 일단 최소한 하나의 교섭의제를 통해 원청 사용자를 교섭의 장으로 나오도록 할 수 있다는 장점이 있는 반면, 교섭의제별로 사용자성에 대한 신속한 판단이 이루어져야 실익이 있다는 어려움도 있다. 실무적으로는 결국 교섭의제별 사용자성이 얼마만큼 충분히 증명될 수 있는가의 문제가 될 것이다. 현실적으로는 원청의 교섭거부 사건이 1차적으로 노동위원회에서 다루어질 가능성이 매우 높다는 점을 고려할 때 노동위원회의 적극적인 직권조사를 통한 증명이 이루어질 수 있도록 하는 방안이 필요할 것이다.

²⁵⁾ 대법원이 원심의 입장을 지지하면서 심리불속행 판결을 내린 사건(대법원 2016. 6. 23. 선고 2016다13741 판결, 원심: 서울고등법원 2016. 1. 15. 선고 2015나2661 판결).

4. 원하청 이외의 다면적 노무제공관계에서 사용자성 판단 기준

원·하청 관계 외에도 다양한 형태의 다면적 노무제공관계가 확산되고 있는 점을 고려하면, 원·하청 관계에서 형성된 사용자성 판단 원칙과 해석 기준은 다른 형태의 간접고용·플랫폼 기반 노동관계에서도 유사하게 적용될 수 있다. 다만 개별 노동관계의 구조, 지휘·명령 방식, 경제적 종속성의 정도, 노동과정 통제 방식 등에 따라 사용자 판단의 구체적 기준은 달라질 수밖에 없다. 예컨대 원·하청 관계에서 하청근로자의 근로조건에 대한 원청의 관여 수준과 지배·결정 능력은 원청-하청-하청근로자로 이어지는 전형적인 삼각 구조 속에서 검토되며, 이는 실체적 노동통제권의 존재 여부를 중심으로 판단된다. 이러한 구조는 온라인 플랫폼-중간사업자(대리점·대행사 등)-플랫폼노동자로 구성되는 플랫폼 노동관계에서도 일정 부분 대응 가능하다.

그러나 원청과 하청의 관계는 플랫폼과 중간대리점 간의 관계와 동일하지 않으며, 플랫폼의 영향력은 알고리즘·데이터 기반 통제, 시장 접근 권한 통제, 업무배정·평점관리·계정 정지 시스템 등 비가시적이고 간접적인 방식으로 나타날 수 있다. 플랫폼은 노무제공 단가와 보상구조를 사실상 결정하는 핵심적 권한을 행사하면서도, 겉으로는 계약상 독립성을 강조하는 방식으로 법적 책임을 회피하는 경향이 있다. 따라서 통상적 의미의 현장 지휘·감독 여부나 물리적 사업장 편입 여부가 낮게 나타날 수 있음에도 불구하고, 실제 노동조건 통제력은 훨씬 더 강하게 작동할 수 있다. 사업체계에 대한 편입성 판단 역시, 물리적 공간 중심 판단에서 디지털 인프라·데이터 네트워크 중심 판단으로 전환될 필요가 있다.

따라서 플랫폼 노동관계에 개정 노조법 제2조 제2호 후단을 적용하는 경우, 플랫폼 구조의 특수성, 알고리즘 통제 방식, 경제적 종속성 및 노동조건 형성 과정의 실질을 세밀하게 고려한 해석이 요구된다. 이러한 접근은 사용자 개념을 형식적 계약 관계에 한정하지 않고, 실질적 노동통제력과 집단적 교섭의 필요성을 기준으로 재구성하는 방향에서 의미를 갖는다고 할 것이다. 다만, 지면관계상 이에 대한 구체적 내용은 본고에서는 더 이상 다루지 않는다.

III. 교섭창구단일화제도에 대한 검토

II.에서는 개정 노조법 제2조 제2호 후단의 해석을 중심으로 사용자성 판단과 관련한 기존 판례의 흐름, 해당 조항 해석의 원칙, 그리고 사용자성 판단 기준에 대해 검토하였다. 이러한 검토를 전제로 할 때, 사용자 개념의 확장은 기존의 단체교섭 구조 전반에 상당한 변화를 요구한다. 우리나라의 전통적 노사관계 질서는 주로 단일 기업 내부를 중심으로 구성되어 왔으며, 노조법 체계 또한 기업 내 노사관계를 기본 단위로 삼아 설계되어 왔다. 대표적으로 교섭창구단일화 제도는 개정 전 노조법 제2조 제2호의 사용자 개념에 기초해 ‘하나의 사업 또는 사업장’ 내 복수노조가 존재하는 경우 단일 창구를 통해 교섭이 이루어지도록 함으로써 교섭의 효율성과 노사관계의 안정성을 확보하려는 목적을 지녔다. 즉 교섭창구단일화제도는 ‘하나의 사업 또는 사업장’ 내 복수의 노동조합이 존재함으로써 발생하는 복수의 교섭요구를 조정·규율하기 위해 ‘하나의 사업주’와 ‘하나의 교섭대표노동조합’의 단체교섭구도를 설정한 것이다.

그러나 노조법 제2조 제2호 후단의 신설로 인해 노동관계를 더 이상 기업 내부의 교섭구조에만 국한하여 파악할 수 없게 되었다. 이에 따라 사용자의 개념적 범위가 확대될 경우 단체교섭의무 역시 복수의 사용자, 기업 외부 사용자, 나아가 다면적 노무제공관계의 사용자에게까지 확장될 수 있다. 지금까지 판례는 이와 같은 변화 가능성을 해석론적 방식으로 점진적으로 확인해 왔으나, 2025년 9월 9일 노조법 개정으로 이 변화 구조가 법제도화된 것이다. 이에 따라 가장 먼저 제기될 수 있는 문제는 현행(2026년 3월 10일 시행 이전) 노조법상 요구되는 교섭창구단일화제도의 적용 문제가 논쟁적이다.²⁶⁾ 이하에서는 이 문제를 중심으로 논해

26) 2025년 11월 25일 고용노동부는 노조법 시행령 일부개정령안을 입법예고 하였는데, 본고 투고일인 11월 20일 당시는 아직 이 시행령 개정령안의 입법예고가 이루어지기 전이었다. 이 시행령 개정안은 교섭창구단일화제도가 노조법 제2조 제2호 후단의 신설 사용자를 기준으로 적용됨에 기초하였다. 이것의 타당성에 대한 검토가 요구될 수는 있지만 본고를 수정하고 있는 2025년 12월 초 현재 시행령 개정안 자체가 입법예고 상태이고, 향후 변경의 가능성도 있으며, 본고가 취하고 있는 해석 입장과 상반된 논리에 기초

보고자 한다.

1. 원하청 교섭 시 교섭창구단일화 적용에 대해 주장 가능한 견해

개정 노조법 하에서 원청사용자와 하청노조 간에 단체교섭을 하게 되는 경우, 교섭창구단일화 절차 적용에 관해서는 다음과 같은 해석론들을 생각해 볼 수 있을 것이다.

- ① 1설: 원청노조와 하청노조 간에는 교섭창구단일화 절차를 거칠 필요가 없지만, 하나의 하청사업 내에 복수의 하청노조들이 있는 경우에 그 하청노조들은 교섭창구단일화를 거쳐야 한다는 견해
- ② 2설: 원청노조와 하청노조 간에 교섭창구단일화 절차를 거쳐야 한다는 견해. 이 경우 원청노조와 교섭을 요구한 해당 하청노조만 교섭창구단일화 절차를 거쳐야 한다는 견해(2-1설)가 있을 수 있고, 어느 하나의 하청노조가 원청사용자에 대해 교섭을 요구하면 원청노조와 모든 하청노조들(즉, 교섭을 요구한 하청노조 외의 다른 하청노조들)이 함께 교섭창구단일화 절차를 거쳐야 한다는 견해(2-2설)가 있을 수 있음.
- ③ 3설: 원청노조와 하청노조 간에는 교섭창구단일화 절차를 거칠 필요가 없을뿐 아니라 하나의 하청사업 내에 복수의 하청노조들이 있다 하더라도 그 하청노조들이 교섭창구단일화 절차를 거칠 필요도 없다는 견해. 3설을 취하는 입장은 기본권 최대보장 원칙에 따라 기본권 제한적 규정은 확장해석이 불가하고, 창구단일화제도에 대한 위헌의견이 높아지는 추세도 고려할 필요가 있다는 점, 창구단일화에 관한 제29조의2에서 정하고 있는 요건인 “하나의 사업 또는 사업장”과 관련하여 원청-하청은 별개 사업장이라는 점, 창구단일화의 목적은 교섭 효율성 확보인데 이해관계 다른 원·하청 강제 통합은 비효율을 야기하므로 오히려 효율성을 저해한다는 점,

하고 있으므로 시행령 개정안에 대해서는 향후 이것이 확정되어 시행된 후 확정된 내용에 기초해 검토하고자 한다.

권리의 행사방법과 권리행사에 따른 리스크는 권리자 스스로 판단할 문제이고 국가, 사회는 권리자의 권리행사를 존중하는 것이 1차적 자세이므로 교섭혼란의 우려는 노조 스스로 산별노조 구성이나 공동교섭단 구성 등을 통해 노사 자치로 해결할 수 있다는 점 등을 들고 있다.²⁷⁾

1) 1설 검토

교섭창구단일화 절차에 대해 규정하고 있는 현행 노조법 제29조의2 제1항은 “하나의 사업 또는 사업장에서 조직형태에 관계없이 근로자가 설립하거나 가입한 노동조합이 2개 이상인 경우 노동조합은 교섭대표노동조합(2개 이상의 노동조합 조합원을 구성원으로 하는 교섭대표기구를 포함한다. 이하 같다)을 정하여 교섭을 요구하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 제2항은 “다만, 제3항에 따라 교섭대표노동조합을 자율적으로 결정하는 기한 내에 사용자가 이 조에서 정하는 교섭창구 단일화 절차를 거치지 아니하기로 동의한 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다.

여기서 우선 노조법 제29조의2에서 말하는 “하나의 사업 또는 사업장”이 (1) 원청사업과 하청사업을 합하여 하나의 사업으로 볼 것인지, (2) 원청사업과 하청사업을 각각의 사업으로 볼 것인지를 검토할 필요가 있다.

(1)의 경우에는 원칙적으로 원청사업과 하청사업은 합하여 하나의 사업이기 때문에 원청노조와 하청노조 간에 교섭창구단일화 절차가 진행되어야 하고 (2)의 경우에는 원청사업과 하청사업이 별개의 각 사업이기 때문에 하청사업 내의 노조들 간에 교섭창구단일화 절차를 진행하면 될 뿐 원청노조와 하청노조들이 교섭창구단일화 절차를 진행할 필요는 없다고 해석된다.

“하나의 사업 또는 사업장에서 ... 노동조합이 2개 이상인 경우”에 교섭창구단일화 절차가 적용되도록 규정하고 있는 노조법의 문언에 충실하게 해석한다면 노동조합의 관점에서는 하나의 사업(장) 내에 2개 이상

27) 김린, 앞의 글, 19쪽.

의 노동조합이 있는가라는 점이 문제된다. 또한, 노조법 제29조의 3 제1항에서는 “제29조의2에 따라 교섭대표노동조합을 결정하여야 하는 단위는 하나의 사업 또는 사업장으로 한다.”라고 규정하고 있고, 교섭창구단일화 제도는 사용자가 아니라 교섭단위인 “사업 또는 사업장”을 대상으로 적용된다고 해석될 수 있다.²⁸⁾

이와 같은 입장을 취한 중앙노동위원회 2022. 3. 24. 판정 중앙2021부노268 사건에서 중앙노동위원회는 “사내하청 근로자들로 조직된 노동조합의 단체교섭 상대방이 사내하청 사용자뿐만 아니라 원청 사용자까지 확대되더라도 단체교섭 대상은 사내하청 근로자들의 노동조건임에는 변화가 없으며 근로자들의 이해관계의 공통성을 기반으로 교섭대표노동조합을 정해야 하는 교섭단위는 사내하청 근로자들이 종사하는 ‘하청 사업’으로 그대로 유지된다.”라고 하고, “사내하청 근로자들이 가입 내지 조직한 노동조합이 ‘하청사업’이라는 교섭단위에서 교섭창구 단일화 절차를 거쳤다면 노동조합법에서 요구되는 교섭창구 단일화 의무를 충족한 것이라고 보아야 할 것이고, 이러한 교섭창구 단일화 절차를 거쳐 확정된 교섭대표노동조합은 하청 사용자뿐만 아니라 하청근로자의 노동조건에 대해 실질적이고 구체적인 지배·결정력을 가지는 원청 사용자에게도 교섭을 요구할 수 있다고 보아야 할 것이다.”라고 밝혔다.

서울행정법원은 위와 같은 중앙노동위원회 판정에 대해 명시적인 견해를 밝히지는 않았지만 판정의 적법성을 인정하면서 “근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권은 헌법의 규정만으로 직접 법규범으로서 효력을 발휘할 수 있는 구체적 권리이고 단체교섭 및 단체협약 체결 과정에 대하여는 구체적인 법률로 정하지 않고 노사간에 자율적으로 정할 사항으로 남겨둘 수도 있는 것이므로(헌법재판소 2002. 12. 18. 선고 2002헌바12 결정 참조), 실질적 지배력설에 따른 사용자 개념의 해석이 노동조합법상 교섭창구단일화 절차 등의 관련 규정들에 의해 온전히 포섭되지 못하는 측면이 있다 하더라도, 그러한 사정이 근로자의 헌법상 기본권인 단체교섭권의 행사 범위를 제한하는 근거가 될 수는 없다.”, “교섭창구 단일화는 근로자 측의 조직 형태가 복수인 경우 사용자 측의 대응 가능

²⁸⁾ 중앙노동위원회 2022. 3. 24. 판정 중앙2021부노268((현대제철 사건)의 입장.

성과 교섭 효율성을 고려한 절차 규정이지, 단체교섭권 자체를 제한하는 규범이라고 볼 수 없으므로, 교섭창구 단일화 제도를 이유로 하여 실질적으로 사용자 지위에 있는 자와의 교섭 자체를 원천적으로 배제하는 것은 헌법에서 단체교섭권을 기본권으로 보장하고 있는 취지와 정면으로 충돌한다.”라고 판시했다.²⁹⁾

1설에 대해서는 “법은 기업이라는 경계를 넘어서려 하는데, 절차는 다시 기업 단위로 회귀시키려 한다”는 비판이 제기되는바,³⁰⁾ 일응 타당한 지적이라고 할 수 있다. 다만, 제도의 당부당을 떠나 교섭창구단일화 제도가 법에 존재하는 상황에서 하나의 사업 내에 복수노조가 있는 경우에 교섭창구단일화 절차를 전혀 거치지 않아도 된다고 하는 것은 법 문언에 비추어 볼 때 다소 무리한 해석이라고 생각한다.

2) 2설 검토

원청노조와 하청노조가 교섭창구단일화 절차를 통해 교섭대표노조를 정해야 한다는 2설의 입장을 취한다면, 하청노조의 수적열세로 인해 하청노조가 교섭대표노조가 될 가능성은 거의 없을 것이다. 또한 공동교섭대표단을 구성하는 경우에도 “공동교섭대표단에 참여할 수 있는 노동조합은 그 조합원 수가 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합의 전체 조합원 100분의 10 이상인 노동조합으로 한다.”라는 노조법 규정으로 인해 하청노조는 역시 수적 요건 미충족으로 배제될 가능성이 높다.

그리고 2설의 경우 앞서 언급한바와 같이 원청노조들은 어느 하나의 하청사업에 설립되어 있는 하청노조가 원청사용자에게 단체교섭을 요구할 때마다 매번 교섭창구단일화 절차를 거쳐야 하는 것인가(2-1설), 아니면 어느 하나의 하청사업에 설립되어 있는 하청노조가 원청사용자에게 단체교섭을 요구하면 각 하청사업에 설립되어 있는 모든 하청노조들과 원청노조들이 다함께 교섭창구단일화 절차를 거쳐야 하는 것인가(2-2설)라는 점이 문제될 수 있다. 2-1설의 경우는 개정 노조법에 따른 문제점

29) 서울행정법원 2025. 7. 25. 선고 2022구합69230 판결.

30) 김린, 앞의 글, 19쪽.

이라고 지적되고 있는 비효율성을 더욱 증폭시킬 것이고, 2·2설의 경우는 어떤 법적 근거로 각기 다른 사업에 설립되어 있는 각 하청노조들과 원청노조들을 다함께 모아 교섭창구단일화 절차를 거치도록 할 수 있는 것인가라는 의문이 제기된다. 노조법 시행령이 규정하고 있는 사용자의 교섭요구사실에 대한 공고 등의 실질적 작동 방법도 예상하기 어렵다.

한편, 2설은 하청노조들에게 법 개정 이전보다 오히려 복잡한 절차를 거치도록 강제하고, 자율적인 교섭보다는 노동위원회 등 행정기관의 주도에 의해 교섭이 통제되도록 함으로써 법 개정의 의미를 퇴색시킬 수 있다는 문제점이 있다. 또한 노조법 제2조 제2호 후단 신설 사용자는 전단 사용자와 다른데, 동조 전단 사용자를 전제로 규정된 교섭창구단일화 제도가 후단 사용자 개념 신설에도 불구하고 당연히 적용되어야 한다고 해석하는 것은 법 체계적으로 정합적이지 못하다.

다만, 2설을 취하는 경우에 현실적으로는 원청노조와 하청노조는 교섭단위 분리절차를 통해 각각 원청사용자와 교섭하는 방안이 고려될 수 있을 것이다.³¹⁾

3) 3설 검토

3설은 교섭창구단일화절차가 개정 노조법과 같은 원하청 교섭이 가능한 상황을 전혀 고려하지 않고 만들어진 제도이기 때문에 개정 노조법 하에서의 원하청 교섭에 대해서는 적용할 수 없다는 문제의식에서 출발하는 견해이고 타당한 면도 있다. 그렇지만 교섭창구단일화제도는 원칙적으로 하나의 사업 단위로 적용되는데 하나의 하청사업 내에 복수 노조가 있는 경우에 하나의 사업 내에 복수 노조가 있음에도 불구하고 교섭창구단일화 절차를 전혀 거치지 않은 채 각각의 노조가 원청사용자에

31) 이와 관련하여 이승욱 교수는 개정 노조법과 관련하여 “교섭창구단일화절차에 관한 노동조합법령의 대폭적인 정비와 필요불가결하다.”라고 하면서 그것이 현실적으로 불가능하다면, 당분간은 교섭단위분리제도를 활용하여 교섭을 진행해야 한다는 의견을 제시하고 있다(이에 관한 상세한 내용은 이승욱, “노동조합법 제2·3조 개정의 쟁점과 향후 과제 - 미국과의 비교를 중심으로 -”, 『노동법학』 제95호, 한국노동법학회, 2025, 53쪽 이하 참조).

게 개별교섭을 요구할 수 있는 법적 근거가 무엇인지 설명하기 어렵다.

4) 소결

교섭창구단일화 절차는 하나의 사업 또는 사업장에 2개 이상의 노조가 있는 경우에 적용되는 절차로 법에 규정되어 있고, 노조법 제29조의3은 “제29조의2에 따라 교섭대표노동조합을 결정하여야 하는 단위는 하나의 사업 또는 사업장으로 한다.”라고 규정하고 있다는 점에서 교섭창구단일화 제도는 교섭단위인 “하나의 사업 또는 사업장”을 대상으로 적용된다고 해석할 수밖에 없다고 생각된다. 따라서 하청사업에서 2개 이상의 노동조합이 조직되어 있다면 하청사업에서 교섭창구단일화 절차를 거친 교섭대표노동조합이 원청사용자를 상대로 교섭요구를 할 수 있다고 봄이 법 문언에 충실한 해석이라고 할 것이다.

그리고 무엇보다도 법률에 의해 창설된 제도인 교섭창구단일화제도로 인해 헌법상 노동3권이 제한된다면 이는 본말이 전도되는 상황이 될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다. 개정 노조법은 하청노조의 실질적 교섭권 보장을 위한 취지를 담고 있다는 점을 고려할 때 가급적 하청노조가 원청사용자와 자유롭게 교섭할 수 있는 방향으로 해석되어야 할 것이다.

참고로, 서울행정법원 2025. 10. 30. 선고 2024구합72896 판결에서는 “다면적 노무제공관계를 통하여 복수의 사용자와 실질적인 노무제공 관계가 형성되어 있는 경우에는 그러한 구조적 실태를 반영하여 더욱 탄력적이고 현실적인 교섭단위 설정이 인정될 필요가 있”다고 하여 다면적 노무제공관계에서의 교섭창구단일화제도 적용이 보다 유연하게 해석되어야 할 필요성이 지적되고 있다.

한편, 개정노조법 하에서 사용자범위 확대에 따른 교섭창구단일화제도 문제는 교섭창구단일화제도의 폐지가 본질적인 해결방안이 될 수 있을 것이다. 다만, 존치를 전제하였을 때 이 제도가 기업 내 노사관계상 “조직대상을 같이하는” 복수노조를 예정하고 만들어졌다는 점(복수노조 금지체제 하에서도 기업별 노조와 별도로 조직대상을 달리하는 노동조합 설립은 금지되지 않았음),³²⁾ 교섭창구단일화제도 형성 당시 산별 교

섭 구조 등 초기업적 수준에서의 교섭관행이 형성되지 않았었다는 점 등을 고려해 기업단위 노동조합과 사용자간의 단체교섭을 제외한 영역에서는 적용되지 않는다고 해석하는 것이 사용자 개념 확대와 함께 요구된다.

초기업단위 노동조합의 지부나 분회는 원칙적으로는 노동조합이라고 보기 어렵기 때문에 단체교섭권을 갖지 않는다고 볼 것인데, 현행 판례와 해석의 태도와 같이 단체교섭권의 위임 등에 의해 독자적 노동조합으로서 지위를 갖는다고 해석함에 따라 해당 지부나 분회가 기업내 노사관계체제 하에서 단체교섭을 진행하고자 하는 경우에는 교섭창구단일화제도의 적용을 받는다고 할 것이다. 그러나 원하청관계에서 하청회사 노동조합이 원청회사를 상대로 단체교섭을 요구하는 경우, 하청회사들의 노동조합들이 원청회사를 상대로 단체교섭을 요구하는 경우 등에는 기반을 달리하는 노동조합간 교섭창구단일화제도의 영향을 받지 않는다고 해석하는 것이 합리적이다. 원하청 노동조합들의 공동교섭 등의 방법을 선택할 수도 있을 것이지만, 공동교섭이 불가능한 상황에서는 개별교섭이 원칙이라고 볼 수밖에 없다.

2. 입법론적 개선방안

하청노조와 원청사업주의 사이의 관계는 마치 산별교섭과 유사한 구조라는 점에서 기업별 노조를 전제로 설계된 교섭창구단일화절차와는 정합성이 떨어지고, 이에 장기적 관점에서는 입법적 해결 방안도 적극적으로 고려하여야 할 것이라는 견해가 있고,³³⁾ 타당한 지적이라고 생각한다.

위에서 살펴본 판례에서도 “실질적 지배력설에 따른 사용자 개념의 해석이 노동조합법상 교섭창구단일화 절차 등의 관련 규정들에 의해 온전히 포섭되지 못하는 측면이 있다.”라고 지적한 부분에서 현행법이 예정하지 않았던 원하청 교섭에서 교섭창구단일화 절차를 그대로 적용하

32) 대법원 1995. 10. 13. 선고 94다34944 판결 등 참조.

33) 김홍영·권오성·김린·노호창·방강수, 노동분쟁에서 당사자 적격의 판단기준에 관한 연구, 중앙노동위원회 연구용역보고서, 한국노동법학회, 2020, 68쪽.

는 것이 타당한지, 입법적 보완이 필요한 것인지 등의 문제의식을 엿볼 수 있다.

개정 노조법에 따른 사용자 개념 확대에 대한 비판 중에는 “100개의 하청업체가 있는 원청회사는 만일 100개의 하청업체에 모두 노조가 있다면 100개의 노조와 일일이 단체교섭을 해야 하는 것인가?”와 같은 유형의 질문이 있다. 모든 하청업체에 각각 노조가 조직되어 활발한 노조 활동을 함을 전제로 하는 위와 같은 질문의 현실성은 별론으로 하더라도, 그러한 문제 발생의 가능성을 완전히 도외시할 수도 없다. 그런데 이러한 문제는 위에서 살펴본 1설~3설의 방식 중 어느 쪽을 취하더라도 근본적으로 해결되기는 어려운 문제라고 생각된다.

이와 관련한 개선 방안으로 하청업체나 용역업체의 경우 업종이나 근로조건의 유사성 등을 고려하여 여러 사업 또는 사업장을 대상으로 교섭단위를 통합할 수 있는 근거를 마련하는 법 개정도 고려되어야 할 것이다. 이와 관련해 아래와 같은 추가적인 입법을 고려할 수 있다고 생각한다.

첫째, 위에서 살펴본 바와 같이 현재 노조법 제29조의2 교섭창구단일화제도 및 그 절차가 원하청 교섭에서도 요구되는지에 대한 해석이 분분한 바, 현행 노조법 제29조의2는 기업 내 복수노조를 전제함을 분명히 하고 확장된 사용자와 관련하여서는 노조법 제29조의2가 적용되지 않는다는 것을 분명히 할 필요가 있다. 이러한 점을 반영한 법 개정안은 다음과 같다.

(신설) 제29조의3(교섭창구 단일화 절차 특례)

- ① 제29조의2의 교섭창구 단일화 절차는 하나의 사업 또는 사업장 내 복수의 노동조합이 제2조 제2호 전단의 사용자와 단체교섭을 하는 경우에 적용한다.
- ② 노동조합이 제2조 제2호 후단의 사용자와 단체교섭을 하고자 할 때 해당 노동조합이 조직된 사업 또는 사업장 내에 2개 이상의 노동조합이 존재하는 경우에는 해당 노동조합이 해당 사업 또는 사업장 내에서 제29조의2에 따른 교섭대표노동조합이어야 한다.

둘째, 현행 노동조합법 제29조의3 제2항은 “하나의 사업 또는 사업장에서 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등을 고려하여 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합할 필요가 있다고 인정되는 경우에 노동위원회는 노동관계 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽의 신청을 받아 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합하는 결정을 할 수 있다.”라고 규정하여 사업 또는 사업장 내 교섭단위 통합이 가능함을 규정하고 있다. 여기서 더 나아가 여러 사업 또는 사업장을 대상으로 하는 교섭단위 통합제도, 다시 말하여 초기업적인 통합제도는 근로조건 통일, 격차해소, 기업 간 공정경쟁 확보, 근로자 지위 개선 필요성에서 고려되어야 하고, 장기적으로는 초기업교섭 활성화를 도모한다는 의미도 있다.

특히, 현행 노조법에서는 교섭단위 분리제도만 인정하고 있다(교섭단위 통합은 분리 후의 통합만 가능하다). 앞서 제안한 바와 같이 사용자 개념 확대와 함께 단지 기업 내 노사관계를 전제하지 않는다면 복수의 하청기업 간 교섭단위를 통합하거나, 통합한 경우에는 분리할 수 있도록 할 필요가 있다. 자율적으로 교섭단위를 통합해 공동교섭체제를 구성할 수도 있지만 필요에 따라 이에 대한 절차를 규정해줄 필요가 있을 것이기 때문에, 통합 및 분리가능성을 노조법에 명시하고 시행령으로 통합과 분리 절차를 규정하도록 하는 것이 필요하다. 자율적인 통합 가능성을 인정하되, 통합하고자 함에도 노동조합간 적절한 절차와 방법을 찾지 못하는 경우가 있을 수 있으므로 통합을 위한 공적 서비스를 제공하는 의미이다. 이를 위해 노동위원회의 통합결정절차를 마련할 수 있을 것이다. 한편, 교섭단위의 분리는 이미 통합된 교섭단위가 이후의 교섭에서 분리하여 교섭을 진행하고자 하는 경우를 위한 것이므로, 분리절차는 처음부터 노동위원회 결정을 통해 진행할 수 있도록 하는 것이 합리적일 것이다. 이러한 취지를 반영한 법 개정안은 다음과 같다.

제29조의34(교섭단위 결정 등) ① 제29조의2에 따라 교섭대표노동조합을 결정하여야 하는 단위(이하 “교섭단위”라 한다)는 하나의 사업 또는 사업장으로 한다.

- ② 제1항에도 불구하고 하나의 사업 또는 사업장에서 현격한 근로조건의 차이, 고용형태, 교섭 관행 등을 고려하여 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를(삭제) 통합할 필요가 있다고 인정되는 경우에 노동위원회는 노동관계 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽의 신청을 받아 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합하는 결정을 할 수 있다.
- (신설) ③ 제1항에도 불구하고 제2조 제2호 후단의 사용자와 교섭하고자 하는 2개 이상의 노동조합은 자율적으로 교섭단위를 통합한 후 교섭대표노동조합을 결정할 수 있다. 교섭단위가 통합되었음에도 불구하고 교섭단위를 분리해야 할 합리적인 사정이 있는 경우에는 통합된 교섭단위에서 결정된 교섭대표노동조합의 신청에 따라 노동위원회는 교섭단위를 분리하는 결정을 할 수 있다.
- ④ 제2항 및 제3항에 따른 노동위원회의 결정에 대한 불복절차 및 효력은 제69조와 제70조제2항을 준용한다.
- ⑤ 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를(삭제)통합하기 위한 신청 및 노동위원회의 결정 기준·절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

위와 같은 노동조합의 교섭단위 통합과 함께 고려해야 할 것은 근로조건에 대하여 “실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위”에 있는 복수의 사용자를 대상으로 하는 교섭이다. 현행법상 노동조합의 교섭창구단일화는 고려되고 있지만, 노조법 제2조 제2호 후단 신설에 따라 동일한 근로조건에 대해 복수의 사용자가 이러한 “실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위”에 있는 경우에는 복수의 사용자 또한 노동조합과 마찬가지로 ‘교섭대표’를 구성해야 함을 요구해야 하는 것은 아닐까?

IV. 결론

개정 노조법 제2조 제2호 후단의 사용자 개념 판단은 헌법상 노동3권 보장의 관점, 즉, 헌법상 기본권인 단체교섭권을 구체적으로 실현하는 관점, 노무제공관계의 실질에 비추어 노동3권을 침해할 수 있는 권한·지위에 있는지의 관점, 사내하청업체 근로자들의 노동조건 등을 원청과의 단체교섭에 의해 집단적으로 결정할 필요성과 타당성이 있는지 여부 등을 기본 토대로 하여 판단하여야 할 것이다. 법원은 근로자파견의 판단 기준 중 일부 기준과 유사한 내용을 노조법상 사용자 판단기준으로 사용하고 있는데 근로자파견 판단과 노조법상 사용자 판단은 구분되어야 하고 근로자파견 판단기준과 유사한 기준을 사용하는 경우 노동3권 보장 관점에서의 노조법상 사용자 판단이라는 기본 틀이 흔들리지 않도록 유의해야 한다.

그리고 기존 판례는 개별 사건에서 원고와 피고가 주장한 모든 사실에 대해 검토하여 판단을 내리게 된 것이라는 점에서 기존 판례에서 언급된 판단의 근거들이 보편적인 판단기준 내지 판단요소로서 일반화될 수 없다는 점에 유의할 필요가 있다. 즉, 기존 판례에서 도출해낼 수 있는 특징과 시사점을 분석, 고려하는 것은 필요하지만 각각의 사건에서 법원이 판단의 근거로 삼은 사실들을 곧바로 일반적 판단기준으로 인정할 수는 없다는 점이다. 특히 원청의 사용자성을 인정한 판결의 경우에는 사용자성을 인정하기 위해 최대한 많은 사실관계들이 판단의 근거로 설시되는 특징이 있다. 따라서 ‘어떠어떠한 사실들이 인정되므로 사용자성이 인정된다’라는 판결의 취지가 ‘어떠어떠한 사실들이 인정되어야 사용자성이 인정된다’로 읽혀서는 안 된다.

한편, 현행 노조법상 교섭창구단일화 제도는 원하청 교섭을 고려하지 않은 제도라는 점에서 이 제도를 원하청 교섭에 그대로 적용하는 것이 타당한 해석론인지 의문이 제기된다. 다만 현행 노조법 문언의 해석상 교섭창구단일화제도는 하청사업 내에 2개 이상의 하청노조가 조직되어 있는 경우 그 하청노조들 간에 거치면 된다고 본다. 입법론적으로는 여러 사업 또는 사업장을 대상으로 하는 교섭단위 통합제도를 도입하여

다수의 하청노조들이 교섭단위 통합을 통해 원청과 교섭할 수 있도록 하는 방안이 필요하다고 생각된다.

주제어: 사용자 개념 확대, 실질적·구체적 지배·결정, 다면적 노동관계, 단체교섭, 교섭창구단일화 제도, 원청-하청 단체교섭

참고문헌

- 김민기, 『사내하청에 대한 노동법적 규율』, 서울대학교 박사학위논문, 2023.
- 김유성, 『노동법Ⅱ』, 법문사, 2000.
- 김철수, 『헌법학개론』, 박영사, 1992.
- 김홍영·권오성·김린·노호창·방강수, 『노동분쟁에서 당사자 적격의 판단기준에 관한 연구』, 중앙노동위원회 연구용역보고서, 한국노동법학회, 2020.
- 김형배, 『노동법』, 박영사, 2003.
- 심현우, 『기본권 대사인적 효력에 대한 직접효력설의 적정성 검토』, 고려대학교 석사학위 논문, 2022.
- 이병태, 『노동법』, 중앙경제, 2001.
- 임종률, 『노동법』, 박영사, 2004.
- 장영수, 『헌법학』, 홍문사, 2021.
- 전광석, 『한국헌법론』, 집현재, 2018.
- 김 린, “개정 노동조합법 제2조 시행의 쟁점과 과제—실질적 지배력, 입증책임, 교섭절차를 중심으로 —”, 『노동조합법 제2조 개정과 단체교섭의 새로운 지평-‘노란봉투법’ 이후의 과제-』, 한국고용노사관계학회 2025년 추계 정책토론회 자료집, 2025. 10. 30.
- 김선택, “사법질서에 있어서의 기본권 효력”, 『고려법학』 제39권 제39호, 고려대학교 법학연구소, 2002.
- 박귀천, “‘근로자과견성’ 판단 기준 제정립의 모색 - 판례에 대한 분석을 중심으로”, 『노동법포럼』 제27호, 노동법이론실무학회, 2019.
- 박제성, “사내하청의 담론과 해석”, 『노동법연구』 제40호, 서울대학교 노동법연구회, 2016.
- 이승욱, “노동조합법 제2·3조 개정의 쟁점과 향후 과제 - 미국과의 비교를 중심으로 —”, 『노동법학』 제95호, 한국노동법학회, 2025.

<Abstract>

Reconceptualizing the Employer and Redesigning the
Collective Bargaining Framework under the Amended
Trade Union and Labor Relations Adjustment Act

PARK, Kwi-Cheon* · PARK, Eun Jeong**

This article argues that the amended second sentence of Article 2(2) of the Trade Union and Labor Relations Adjustment Act (effective 10 March 2026), which reconceptualizes the statutory definition of the employer, necessitates a structural reconfiguration of collective bargaining frameworks to address increasingly multilayered labour relations. The existing statutory definition merely categorizes employers into three groups—business owners, management representatives, and individuals acting on behalf of the employer—leaving the substantive contours of the concept to judicial and scholarly elaboration. Academic theory and case law have long recognized that entities other than the contractual employer may constitute employers for the purposes of collective bargaining and unfair labour practice liability when they exercise substantial influence over working conditions. In decisions involving Hyundai Heavy Industries, construction daily workers, Samsung Electronics Service, and parcel delivery and manufacturing subcontracting arrangements, courts and labour commissions assessed substantive control over working conditions, functional organizational integration, the application of internal regulations and safety systems, statutory joint liability, economic dependency, and issue-specific influence over bargaining agendas in

* Professor, Law School, Ewha Womans University

** Professor, Department of Law, Korea National Open University.

determining whether principal contractors qualified as employers.

The amended provision codifies this jurisprudential trajectory by stipulating that an entity not party to an employment contract may nonetheless be deemed an employer when it substantially controls or determines working conditions. Accordingly, the employer in collective labour relations may include contractual employers, service-providing employers, and functional third-party employers lacking direct contractual privity. Determination of employer status must be grounded in the constitutional guarantee of collective bargaining rights. Working conditions must be understood broadly to include occupational safety and health, welfare benefits, employment status, major managerial decisions, and algorithmic management systems governing labour processes.

The concept of substantial control encompasses legal, organizational, and technological mechanisms, such as subcontracting arrangements, operational directives, pricing and remuneration systems, production planning, resource allocation, and digital or algorithmic infrastructures. Multiple employers may coexist with respect to the same working conditions, requiring issue-specific analysis. This framework extends to platform – intermediary – platform-worker relations, where algorithmic management and economic dependency operate as distinct mechanisms of control.

Such expansion necessitates restructuring collective bargaining structures. The enterprise-based single bargaining-channel system cannot accommodate multilayered employer structures and should be confined to situations involving multiple unions within subcontracted workplaces, thereby enabling representative unions to bargain with principal firms. Unified cross-enterprise single-channel rules risk procedural inefficiency and union exclusion. Therefore, legislative reforms enabling bargaining-unit integration across subcontracting structures are required to ensure meaningful collective bargaining.

Key Words: Expanded concept of employer; substantial and concrete control or determination; multi-layered labour relations; collective bargaining; single bargaining-channel system; principal-subcontractor collective bargaining